

CM Droit public des affaires

L'État s'est construit sur son économie → l'État n'est pas nature lié au monde des affaires, et on pourrait aussi dire que c'est le monde des affaires qui est par nature lié à l'État.

Le DPA est Encadrement juridique des actions de l'État sur les affaires économiques → on appelait pendant longtemps le Droit public de l'économie.

La matière a bcp changé depuis 40 ans, avec l'introduction de la concurrence dans le droit positif → depuis 40 ans on parle moins d'économie que de l'opérateur économique qui est celui qui exerce une activité économique.

C'est pour cela que l'on parle d'un droit public des affaires qui est le droit des relations entre la puissance publique et les opérateurs économiques.

Qu'est-ce que l'activité économique = c'est une notion du DUE, c'est la notion centrale du droit du marché. Le DUE appréhende l'activité économique de la manière la plus large possible ; en DUE, l'activité économique est « toute activité de production bien et de service, peu importe son but lucratif ou non, et peu importe, en outre, le statut de la personne qui est chargée de cette activité ».

On considère que l'État intervient de 3 façons dans les activités économiques :

- Il intervient en tant que puissance publique, il encadre juridiquement une activité économique, soit en aidant par des subventions
- La puissance publique peut-être elle-même opérateur économique, elle peut elle-même exercer une activité économique. → Ces activités économiques au niveau local et, de moins en moins, au niveau national (par exemple : en matière de transport).
- L'intervention publique dans l'économie → l'idée de collaboration de la puissance publique avec des OE. → Par le biais de contrat qui vise à satisfaire les besoins des PPB → ce sont les contrats de la commande publique

Introduction

Section 1. L'évolution de l'intervention de la puissance publique

L'État français est entre interventionnisme et libéralisme qui ont souvent nécessité de trouver des compromis.

Paragraphe 1 : L'Ancien Régime

L'ancien régime et le colbertisme → l'État va s'attribuer de nouveaux pouvoirs, notamment en matière économique, des pouvoirs qui sont des attributs de la souveraineté → on va édicter de la monnaie, prélever des impôts → apparaissent à cette époque les premières réglementations économiques professionnelles

L'État n'était jusqu'alors par un opérateur économique, il n'y avait pas des entreprises publiques

Colbert qui considère que la puissance de l'État repose sur sa monnaie et que c'est cette monnaie qui va permettre à l'État de mener une impulsion industrielle → c'est à cette époque que les premières règles sur l'intervention économique vont émerger.

Vont apparaître pour la première fois une administration économique → un Bureau des commerces en 1670, une inspection des manufactures

Puis, sous Colbert va apparaître les premières réglementations des activités économiques privées → l'objectif n'est pas tant d'encadrer les opérateurs que

C'est pour résister à la concurrence européenne que les réglementations vont vouloir

Réglementation très critiquée à cette période → Colbert est très critiqué par les physiocrates au XVIIIe siècle → notamment sur la liberté économique et le droit de la propriété – bien que ces droits ne soient pas encore consacrés.

A cette époque les professions vont s'organiser autour de corporation qui permettent une autogestion de ces professions

→ Permettait notamment de négocier avec le roi → c'est la profession qui va s'encadrer elle-même.

Paragraphe 2 : l'État libéral

Mais cette phase va prendre fin avec la naissance de l'État libéral. En effet, en 1791, le constituant va complètement réformer l'organisation de l'ancien régime → suppression des corporations, avec la loi Le Chapelier le 14 juin. → Réglementation ambiguë car le décret d'Allarde notamment consacre la liberté professionnelle mais indique qu'elle ne s'exerce que dans le cadre des règlements existants → en d'autres termes, bien que les corporations soient supprimées, cela n'empêche pas l'existence d'un corps de règle dans les professions

Dans ce cadre, va être consacré la liberté du commerce et de l'industrie qui est évidemment supprimé du fait de la loi le Chapelier → cette liberté va surtout être consacré par le décret d'Allarde qui est un texte du 2/17 mars 1791.

Vont être consacré à cette période les grands textes du libéralisme → une grande aire du libéralisme va exister dans les pays européens → l'idée que les États sont inutiles dans le cadre des activités économiques. → XVIIIe siècle.

Paragraphe 3 : le retour de l'interventionnisme

Il est réapparu dans les années 1930 et l'État se voit confier une mission de protection des individus contre la crise économique. L'État n'est pas seulement le gardien du marché mais aussi des défaillances du marché, il intervient pour diminuer

les effets négatifs du marché. Les Etats ont fortement agi pour réduire les effets de la crise économique, une action qui a conduit l'Etat français à financer les activités économiques en période de crise. Cette idée de recapitaliser les entreprises privées est la même que lors de la crise de 2008.

Une intervention de la puissance publique est donc quand même utile dans certaines situations.

Se développe également une activité économique administrée par la puissance publique pendant l'entre-deux-guerres, qui se transforme en dirigisme économique après la 2nd GM, l'Etat est directeur du fonctionnement des marchés et plus seulement interventionniste.

Ces interventions sont conjoncturelles, liées à la volonté de reconstruire le pays mais certaines sont toujours actuelles.

Une planification de l'économie a été mise en place, c'est l'idée des plans décennaux ou sur le plus long terme. C'est une idée inspirée des soviétiques à l'époque et ces plans existent toujours aujourd'hui en matière économique.

Ont été instituées de très fortes réglementations de l'économie telles que la réglementation des prix instituée en 1945 par l'ordonnance du 30 juin 1945 dans laquelle il n'y avait aucune liberté en France, la puissance publique fixait les prix sur le marché. La liberté des prix a du attendre 1986.

La puissance publique encadre des marchés particuliers liés à l'idée de souveraineté comme le texte relatif au pétrole ou en matière de défense. C'est à cette période qu'apparaissent des réglementations très strictes dans des domaines stratégiques.

L'apparition d'une véritable administration économique :

Le ministère de l'économie en France existe depuis 1918 et c'est surtout après la 2nd GM que sont créés des EPIC qui sont des entreprises publiques. C'est à cette période qu'apparaissent aussi les chambres de commerce au niveau local, elles ont pour fonction d'accompagner les opérateurs économiques et gèrent les aéroports au niveau local.

En 1941 est créée la commission de contrôle des banques et en 1977 est apparue la commission de la concurrence. C'est l'ancêtre de l'actuelle Autorité de la concurrence qui garantit le bon fonctionnement des marchés.

L'Etat est devenu un véritable opérateur économique et a commencé à gérer des entreprises publiques du fait de vagues de nationalisation importantes.

Après la 2nd GM, on inscrit certains principes dans la constitution. L'alinéa 9 du préambule de 1946 indique que les monopoles de fait ou les services publics nationaux doivent être la propriété de l'Etat et est le fondement des politiques de nationalisation. Ce texte a permis la consécration de la nationalisation en droit positif. Mais ce n'est pas la seule évolution juridique à cette époque, se développent les SPIC qui ont émergé en 1920 avec l'affaire du bac d'Eloka. Le juge va assouplir les conditions de création d'une activité économique suite à l'arrêt CE, Nevers, 1930.

Paragraphe 4 : l'État régulateur

L'État régulateur résulte du déclin de l'interventionnisme dans les années 70, peut être dû à la redécouverte des travaux d'Hayek → avec cette idée que l'intervention de l'État perturbe plus l'économie qu'autres choses.

Ce déclin s'est traduit par des textes portant au niveau national et international

Au niveau international, on peut citer le traité de Rome et tous les autres de l'UE → cette union s'est construite sur des principes très libéraux, dont le principe de non-concurrence → consacré depuis 1957.

Ce principe a été réinterprété depuis les années 70/80 dans un sens qui vient limiter les interventions de l'État dans l'économie.

D'ailleurs l'UE n'a pas de compétence en matière de politique économique → mais elle dispose d'une compétence exclusive en matière de concurrence.

Très clairement l'UE a limité l'activité des États dans l'économie

Avant l'UE l'État pouvait tout faire dans l'économie → depuis l'UE c'est très encadré. Cette intervention doit aujourd'hui être justifiée, dans un but d'intérêt général et proportionnée (intervenir que lorsque cela est nécessaire) → ne pas porter une atteinte excessive aux activités économiques.

Très clairement la compétence économique de l'UE a modifié l'intervention de l'État dans l'économie. 2 illustrations :

- Le DUE prohibe les aides économiques aux entreprises car cela perturbe le fonctionnement du marché ; elle rompt l'égalité entre opérateurs économiques.
- Les grands services publics, les services de réseau comme la Poste, France télécom, Edf, ont été longtemps gérés en tant que monopole par la France → dans les années 80, le DUE a considéré que c'était excessif et a imposé de casser ces monopoles publics et de libéraliser ces marchés, c'est-à-dire les ouvrir à la concurrence.

Très clairement le DUE est un droit d'origine néolibéral, qui vient réduire le rôle de l'État à un rôle minimum.

→ Le droit interne a également évolué, notamment après un texte du 1 décembre 1986, l'ordonnance sur la liberté des prix et de la concurrence → elle met fin à la régulation tarifaire qui existait avant cette date. → C'était très important car lorsque l'État fixe les prix, cela veut dire que le marché ne fonctionne pas car le prix doit normalement être le résultat de la rencontre de l'offre et la demande

En 1986 on admet donc que le marché peut fonctionner sans cette intervention.

Ce texte garantit également la concurrence sur le marché → il vient interdire pour la première fois des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent au marché :

- L'abus de position dominante
- Les ententes anticoncurrentielles entre entreprises

Ces évolutions vont avoir une conséquence fondamentale en 97 → le CE va rendre une décision très importante, décision **Million et Marais, section 1997** : le juge va

considérer que les règles du D privé de la concurrence sont opposable à la puissance publique.

Cela signifie que pour le CE la puissance publique (PP) ne peut pas placer un opérateur en situation anticoncurrentielle.

La PP doit donc respecter la concurrence sur le marché, la concurrence devient une limite à l'intervention de l'État sur le marché.

Le CE a même affirmé plus tard que la concurrence sur le marché relève de l'intérêt public → en d'autres termes, on doit comprendre que depuis les années 80, la concurrence est devenue un élément de l'intérêt général.

Mais aujourd'hui l'État doit concilier cette concurrence avec d'autres éléments de l'intérêt général.

L'État régulateur est un État qui respect les libertés économiques, → Malgré ces libertés économiques, l'État intervient sur le marché quand cela est nécessaire

L'État régulateur s'est traduit par de nombreux changements :

L'État est de moins en moins entrepreneur : l'État est de moins en moins intervenant économique, il y a de moins en moins d'entreprise publique.

Mais plus encore, la PP est soumise depuis plus de 30 ans aux lois du marché, la PP a l'obligation de respecter l'égalité de concurrence entre opérateur économique.

Enfin, on a constaté que la législation de l'UE a conduit à une libéralisation mais aussi à une dérèglementation dans certains domaines → la liberté d'établissement et la liberté de prestation de service a conduit une plus grande extension de secteurs d'activité → comme les enchères.

L'État est devenu garant du fonctionnement du marché mais est de moins en moins un opérateur économique

→ La seule chose qui n'a pas changé est le rôle de l'État en matière de crise → le rôle de l'État devient très fort en période de crise

Section 2. Les mutations du DPA

Le DPA est le droit des relations entre la PP et les opérateurs économiques (public ou privé).

Le droit qui s'applique à la PP est très souvent du droit privé → Le droit privé est très souvent application à l'intervention publique dans l'économie.

Le DPA est aussi un peu du droit privé → on s'intéresse à la vie dans l'entreprise, au droit privé des contrats.

Le DPA est aussi très souvent l'application de décisions du droit administratif et du droit constit → mais ce sera mis en œuvre par des personnes privées.

Plus encore, ces règles du droit administratif ont tendance à évoluer dans le domaine économique → on dit parfois qu'il est le laboratoire du droit administratif, c'est là où

des décisions très originales sont données puis traduites dans tous les domaines administratifs → Le principe de sécurité juridique par exemple s'applique dans le secteur privé et dans le DUE

Pour le reste, le DPA est avant tout l'application de règles de droit administratif (DA).
→ La PP intervient par des actes unilatéraux, des règlements dans les domaines du DPA, même si les contrats sont de plus en plus utilisés.

On va alors parlé de bcp de règles du DA → la question est davantage de la spécificité ou non des règles de ma matière du DPA, est ce que c'est un droit original, qui à ses propres règles ? → on répondra dans le paragraphe 2

Paragraphe 1 : la mutation des sources du droit des affaires

Pendant longtemps on considérait que le DPA était un droit interne, car les sources étaient nationales, et un droit subalterne, car les sources étaient jusqu'aux années 70 de sources réglementaires et infraréglementaires.

Aujourd'hui on peut constater une double évolution et une double élévation des règles du DPA :

D'abord au niveau national : depuis 40 ans les sources du DPA relève de la loi, qui est exclusivement compétente en matière économique et financière (art. 34 constitution).

On a également constaté une constitutionnalisation de la matière et surtout des principales libertés économiques (liberté d'entreprendre et droit de propriété).
Il n'y a plus rien de subalterne aujourd'hui.

On a aussi remarqué une internationalisation et européanisation de la matière → l'européanisation est fondamentales car en DAP, la grande majorité des règles vient du DUE. → Exemple : celui du droit de la commande publique. Depuis 40 ans, toutes les règles de commande publique sont d'origine européenne.

Non seulement l'UE a réhaussé les sources de la matière, mais on a aussi constaté le développement d'un droit international économique → notamment dans le droit d'OMC → ce droit d'OMC est parfois à l'origine de règles de l'UE. En matière des règles de la commande publique, les règles sont issues d'un accord international qui contient des règles sur la commande publique qui sont communs à tous les États

Il y a une uniformisation du DPA

Paragraphe 2 : La spécificité du DPA

Depuis quelques années, en JP constit, le CC a établi un lien très clair entre la liberté économique et la concurrence → le CC° a dégagé un concept d'ordre public économique qui a pour fonction de limiter les libertés économiques. Il a précisé ce qu'il entendait par cet OP économique → c'est le fonctionnement concurrentiel d'un marché.

Aujourd'hui on a un OP économique qui a pour fonction de venir limiter les libertés économiques

C'est pour cela que le législateur ne peut pas tout faire en matière économique → il ne peut pas porter atteinte aux libertés économiques, mais il ne peut pas ne pas intervenir en matière économique

Il existe un OP économique qui va permettre de justifier les principales lois qui viennent encadrer l'intervention des opérateurs économiques. → va aussi avoir un impact sur le raisonnement mis en œuvre dans la matière. Aujourd'hui, l'impératif du bon fonctionnement du marché n'est pas absolu, l'ordre public économique doit être concilié avec les autres éléments de l'intérêt général, ce qui va impliquer un changement dans le raisonnement du juge en matière économique. → en matière économique, dès lors qu'il faut concilier 2 principes de même valeur, il faut vérifier la justification, la proportion de cette conciliation.

Il faut vérifier si l'atteinte aux libertés est justifiée et proportionnée. Le juge doit adapter ses méthodes à la matière économique.

En matière de DPA, le juge doit analyser le fonctionnement d'un marché et le juge doit prendre en compte les éléments économiques et avoir des raisonnements de plus en plus poussés. L'analyse économique intègre parfois des règles de droit.

Dès lors qu'on met en face de la puissance publique, le droit administratif va s'appliquer.

Partie 1 : les libertés économiques

Chapitre 1 : les libertés économiques classiques

Sur ce point on va regarder les libertés qui permettent de garantir l'activité économique.

Mais il existe aussi des libertés qui ne sont pas propre aux activités économiques mais permettent leur exercice

Section 1. Les libertés permettant l'activité économique

Ces libertés ne consacrent pas en elle-même l'activité économique mais sont essentiel pour sa réalisation → le droit de propriété, le principe d'égalité et la consécration de la liberté contractuelle.

Paragraphe 1 : le droit de propriété

Il est consacré dans la C°, plus précisément aux articles 1 et 17 de la DDHC → selon la DDHC, ce droit est inviolable et sacré

Il faut attendre 1982 pour que soit rappelé la valeur constitutionnelle du droit de propriété des personnes privées → il a été étendu aux personnes publiques, au niveau constitutionnel.

A. Le droit de propriété des personnes privées (PPV)

Avant 1982 il était ambiguë, car le CC ne s'était jamais prononcé avant les années 80 à propos de ce droit ; par ailleurs, en 1977 un argument portant sur ce droit était allégué devant le Conseil mais il n'avait pas répondu.

→ Une partie de la doctrine considérait jusqu'à la que ce droit n'était pas inviolable et sacré car il a été très souvent limité depuis 2 siècles → dans la doctrine on a donc dit que ce droit n'avait pas le même caractère que celui qui lui était reconnu dans la DDHC.

Le CC° va confirmer de la valeur constitutionnelle de ce droit dans une décision du 16 janvier 1982 → loi de nationalisation, à propos de la loi qui opérait la nationalisation de plusieurs opérateurs économiques.

→ Le CC° devait donc se prononcer sur la valeur juridique de ce droit de propriété. Il va affirmer la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété.

Le Conseil s'est référé aux travaux préparatoires de la C° de 46 → durant laquelle on n'a pas souhaité changer la formule de la DDHC, le CC° relève les évolutions de ce droit depuis la Révolution.

Aujourd'hui il n'y a pas de doute sur cette question → reste que le droit de propriété peut être soit limité dans certain cas, soit privé dans certain cas → la loi peut opérer une privation du droit de propriété.

Ces 2 régimes d'intervention sont très différents :

- La privation de propriété : rejoint 2 techniques de droit public : l'expropriation pour cause d'intérêt public et les servitudes d'urbanismes qui permettent d'inclure un lieu dans le domaine public. → Dans les 2 cas il y a privation du droit de propriété qui est possible dans 2 conditions :
 - Une nécessité publique
 - Il faut que la privation s'accompagne d'une juste et préalable indemnisation.
- L'atteinte au droit de propriété → pour sa part, il est encadré plus soupement. Il doit être justifié par l'intérêt général ; et depuis 2013, il doit être proportionné à son objectif. Ces conditions de l'atteinte au droit de propriété ont été posées par une décision du **11 avril 2013 du Conseil constitutionnel, décision bonus malus énergétique.**

B. Le droit de propriété des personnes publiques (PPB)

Ce droit de propriété connaît un régime original. Ce droit de propriété des PPB a été consacré en 1986 dans la décision des 25/26 juin 1986 du CC°, décision privatisation.

Cette saisine va permettre au Conseil de reconnaître à la PPB un droit de propriété.

Ceci étant, ce droit de propriété des PPB est très différent de celui des PPV.

Ce régime de propriété est encadré par 2 principes qui sont dérogatoires au droit commun :

- Le principe d'insaisissabilité des biens des PPB :

Il a été consacré au travers d'un principe général du droit administratif : **arrêt de la Cour de cassation BRGM, 1957**. → Les biens des PPB ne peuvent pas être saisis car cela serait une atteinte au principe de continuité du service public.

- Le principe d'incessibilité à vil prix des biens de PPB :

Décision de la **Cour de cassation BRGM, 1957** : Ce principe interdit la cession d'une propriété publique inférieure à sa valeur → on interdit donc une cession d'un bien inférieure à sa valeur lorsque la cession est faite à une PPV et que cette cession est faite sans contrepartie. Ce principe ne s'applique pas dans les relations entre PPB, une PPB peut donc très bien vendre à une autre PPB à vil prix, il peut aussi lui donner.

Mais plus encore, on peut céder un bien à un prix inférieur à sa valeur à une PPV à condition qu'il y ait une contrepartie. → **arrêt de section de 1997, décision Commune de Fougerolles**. Le CE va admettre la cession à titre gratuit d'une propriété publique à une PPV → car il y avait une contrepartie suffisante qui était les obligations d'intérêt général à la charge de l'association preneuse du terrain.

Ce droit est essentiel pour l'exercice d'une activité économique.

Paragraphe 2 : le principe d'égalité

A. La consécration du principe

Ce principe est d'abord consacré par un arrêt du Conseil d'État en 1951 → la société des concerts du conservatoire.

Ensuite réaffirmé dans l'arrêt Denoyez et Chorques qui dit que le principe d'égalité implique de traiter de manière identique des situations identiques.

Arrêt de section du **CE, Société Baxter 1997** → Ce principe n'impose pas de traiter de manière différente des situations différentes.

Ce principe d'égalité n'est pas absolu, on peut y déroger en 3 hypothèses :

- Quand la loi le prévoit
- Lorsque l'intérêt général le commande
- Lorsqu'il existe une différence de situation

B. Les applications du principe d'égalité

En 1982, le CC^o nous explique que ce principe est applicable tant entre les Personnes physiques qu'entre les personnes morales → cela implique d'appliquer ce principe aux opérateurs économiques.

Ce principe connaît des applications importantes en DPA → la définition même du principe qui implique qu'il n'est pas possible pour l'État de rompre l'égal concurrence entre opérateurs économiques.

2^{ème} application : la PPB ne peut exercer des activités économiques que dans les mêmes conditions qu'un opérateur privé.

Plus récemment en 2003, le CC[°] a dégagé des principes fondamentaux de la DPA parmi lesquels se trouvent un principe d'égalité devant la commande public, consacré en 2003 par le CC[°] dans une décision « loi de simplification ».

Le principe d'égalité est certes très important mais n'est pas si contraignant pour la PPB.

Apprécier ce qui relève d'une différence de situation est assez délicat → les juridictions donc peuvent faire ce qu'elles veulent pour savoir si oui ou non il y a différence de situation → Ils disposent d'une large marge, une liberté d'appréciation. C'est très subjectif et cela ne permet donc pas d'appliquer très rigoureusement le principe d'égalité.

Le juge peut également faire des références à l'intérêt général → le juge a accordé des avantages à des opérateurs en considération de préserver les bonnes relations économiques et internationales.

Il est très facile pour le juge de trouver un principe d'intérêt général qui permette de déroger au principe d'égalité en matière économique.

Ce principe d'égalité est de plus en plus utilisé depuis 30 ans pour garantir la concurrence entre les opérateurs économiques (OE).

Le juge préfère se fonder sur le principe d'égalité que sur le principe de libre concurrence → car ce dernier principe implique d'opérer une analyse économique complexe alors que le principe d'égalité est plus facile à manier, car il n'implique pas de raisonnement économique → c'est possible car ce principe d'égalité garantit les mêmes choses que le principe de libre concurrence

Paragraphe 3 : Liberté contractuelle

A. La liberté contractuelle des personnes privées

Les juridictions ont reconnu à la liberté contractuelle une valeur législative.

= Décisions du CE qui range cette liberté au rang de l'article 34 de la C[°].

Seule une loi est compétente en matière de liberté contractuelle.

= Cela résulte d'un arrêt du CE, 1969, syndicat des médecins exerçant en groupe

Quelques années plus tard, le CE a érigé ce ppe en PGD (= CE, 1998, Borg warner). Cela signifie que cette liberté a au mieux une valeur législative. Cette valeur des PGD n'est pas certaine (pour certain : supra réglementaire et infra législative et pour d'autre le PGD a une valeur de loi).

Plusieurs décisions du CC va refuser la valeur constitutionnelle à cette liberté contractuelle.

Ces solutions appartiennent au passé puisqu'il a consacré la liberté contractuelle en valeur constitutionnel = CC, 2000 n°437DC : rendu qq mois après que le CE ait lui aussi reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle (= CE, 2000, Paucourt).

Le CE qq années plus tard a consacré cette liberté contractuelle comme une liberté fonda au sens du référé liberté : ordonnance, CE, 2001, commune de Montreuil-Bellay

= En référé liberté, une liberté fonda c'est une liberté de valeur constitutionnelle donc cette ordonnance vient confirmer la valeur constit de la liberté contractuelle.

Article 4 DDHC = fondement de la liberté contractuelle et aussi de la liberté d'entreprendre.

= c'est la liberté en général. Le juge constit fonde de la même façon la liberté contractuelle et celle d'entreprendre.

Qu'est-ce qu'implique la liberté contractuelle pour des personnes privées ?

Cette liberté protège plusieurs éléments. La liberté contractuelle c'est la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Ceci étant c'est aussi la liberté de choisir son cocontractant. Elle implique en outre la liberté de déterminer le contenu du contrat. Cette liberté contractuelle ne s'arrête pas là. Depuis quelques années, cela implique une idée de sécurité juridique des cocontractants, de stabilité des relations contractuelles. Cela implique qu'une loi ne peut pas remettre en cause le contenu du contrat antérieur, en ppe il ne peut pas exister de loi rétroactive en matière contractuelle venant troubler la stabilité des parties au contrat. Cette stabilité est un corrolaire constit mais n'est pas absolu, le législateur peut y déroger dans l'intérêt général.

Une loi ne peut pas remettre en cause la stabilité de la relation contractuelle sauf si l'intérêt général.

= contrat de soutien entre EDF et les producteurs de renouvelable

= aide employer par des contrats et en 2022 il y a la crise de l'énergie donc augmentation du prix de l'électricité. Les producteurs de renouvelable en plus de bénéficier d'une aide, pris important. Une loi est intervenue en 2023 qui est venue limitée les aides publics aux renouvelables et ce texte était d'application rétroactive.

Question de la constitutionnalité de cette rétroactivité : CC, 2025 le CC a considéré que certes il y avait atteinte à la stabilité des relations contractuelles mais il y avait un motif d'IG qui justifier cette atteinte.

Contrôle du juge constit quant aux atteintes à cette liberté : ce contrôle a évolué, avant 2012, le contrôle était restreint, le conseil ne vérifiait que les justifications à l'atteinte de la liberté contractuelle (il vérifiait juste s'il y avait un motif d'IG). Mais depuis 2012, le conseil exerce un contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté contractuelle (il vérifie la justification de l'atteinte par l'IG, il vérifie la proportion de l'atteinte)

= CC, QPC, 2012, association temps de vie

B. La liberté des PPB

La liberté contractuelle des PPB ont aussi valeur constitutionnelle, depuis une décision de 2006 du CC° → décision loi relative au secteur de l'énergie.

La liberté C des PB n'a pas la même portée quant aux PPB, la liberté C des PPB semble moindre que celle des PPV, et ce pour 2 raisons :

- Dans certains cas, la PPB n'a pas le choix de son cocontractant. Il n'aura pas le choix de son cocontractant dans le cadre de la passation d'un contrat de marché public. Un contrat de marché public est conclu suivant une procédure particulière où il y aura des critères et où la PPB attribue des notes aux candidats. Au terme de la procédure, le cocontractant sera celui qui aura obtenu la meilleure note. → En matière de concession ce n'est pas la même chose
- La PPB n'a pas forcément le choix du contenu de son hypothèse → notamment que certaines stipulations contractuelles sont prohibées. → Comme la délégation du pouvoir de police administrative, la délégation d'un pouvoir réglementaire, un contrat ne peut également pas céder un domaine public, ne peut pas contenir une libéralité consentie par une PPB (la PPB ne peut jamais renoncer à une somme d'argent) et puis enfin, le contrat administratif ne peut pas, en principe, contenir de clause compromissoire (qui autorise le recours à l'arbitrage).

Au-delà de ces libertés générales, ont été consacrées propre dans le domaine économique qui viennent garantir l'exercice d'une activité économique

Section 2. Les libertés qui protègent l'exercice d'une activité économique

Liberté consacrée sous forme de principe général du droit administratif → liberté du commerce et de l'industrie consacrée en tant que PGD dans l'arrêt **Daudignac du CE 1951**.

Pendant longtemps ce PGD n'a eu qu'une valeur législative qui permettait donc au législateur de porter atteinte à cette liberté.

Au début des années 80, le CC° a dégagé une liberté équivalente en droit constitutionnel → elle a la même signification mais a une valeur constitutionnelle : la liberté d'entreprendre

Paragraphe 1 : La liberté du commerce et de l'industrie

Cette liberté désigne la liberté d'accéder au marché et la liberté d'exercer une activité sur le marché.

Cette liberté a également un autre corollaire → c'est sur ce fondement qu'a été consacré le principe de non-concurrence entre l'opérateur public et l'opérateur privé

A. La reconnaissance de la LCI

On peut s'interroger sur ce qui est à l'origine de la décision Daudignac → le CE s'est fondé sur un texte pour consacrer ce PGD, un texte important qui est le décret d'Allarde. Décret d'Allarde qui est un des textes qui vient mettre fin au corporation → dès 1951, le CE va viser le décret d'Allarde dans ses décisions, il est vrai que si on lit le décret d'Allarde, il est indiqué qu'« à compter du 1^{er} avril 1791, il sera libre à tout citoyen d'exercer telle profession : art ou métier, qui trouvera bon ».

La consécration est assez ambiguë en 1951 car ce texte est assez peu clair :

- Le décret d'Allarde est un texte de nature fiscale à la base qui vient imposer les personnes se livrant à une activité économique
- Le décret d'Allarde est adopté quelques mois avant la loi le Chapelier qui elle vient supprimer les corporations.

Cette consécration relève d'une volonté prétorienne → Quand un juge consacre un PGD, il consacre un principe étant censé avoir toujours existé, il relève simplement un principe existant dans l'ordre juridique.

La consécration de la liberté du commerce et de l'industrie dans l'affaire Daudignac est remplie d'ambiguïté.

Le CE en a fait une liberté publique au sens de l'article 34 de la Constitution. **CE, 1960, Martial de Laboulaye**

Des décisions semblent accorder une valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie.

La LCI est une règle de compétence, car dès lors qu'elle a une valeur législative, elle implique que la loi puisse y porter atteinte en raison de l'article 34.

Cette liberté connaît un régime particulier car il est admis dans certain cas que le pouvoir réglementaire peut y déroger.

B. La portée juridique de la LCI

1. La compétence de principe du législateur pour restreindre la LCI

Le principe résulte de l'article 34 → Un règlement peut limiter cette liberté si la loi le lui permet. En l'absence de loi, le CE censure systématiquement ce qui porte atteinte à la LCI

2. Le pouvoir réglementaire en limitation de ce pouvoir de liberté

De manière dérogatoire, un simple règlement peut limiter la LCI dans 2 cas :

- Hypothèse de l'utilisation du pouvoir de police administrative : **CE, Daudignac, 1951**, confirme que l'autorité de police peut limiter la LCI dans le but de protection de l'ordre public.

Ces limitations peuvent être assez fréquentes au niveau local. Ce pouvoir de police est strictement encadré par le juge qui exerce un contrôle de proportionnalité (**arrêt Benjamin 1933**)

- Le pouvoir réglementaire peut également intervenir dans le cadre d'une théorie JP, la théorie sur l'état de la législation antérieure. Le CE considère de manière assez constante que si une loi est déjà intervenue pour limiter l'exercice d'une liberté économique, le pouvoir réglementaire redevient compétent pour limiter cette liberté. → La solution résulte de la décision **Martial de Laboulaye, 1960 CE**. Cette décision est extrêmement souple, suivant cette solution il suffit qu'un texte législatif soit déjà intervenu pour limiter cette liberté pour qu'un règlement puisse limiter encore plus cette liberté.

Ex : **CE, 2004, M. Benkerrou** → le pouvoir réglementaire peut venir compléter une loi antérieure.

3^{ème} hypothèse : gestion du domaine public

Elle a été longtemps soumise à la liberté du commerce et de l'industrie. Le CE est revenu sur cette décision : **CE, 2012, RATP**. Cet arrêt concerne la diffusion de journaux gratuits et l'installation du présentoir de journaux

Le juge a dit : « la gestion du domaine public n'est pas susceptible par elle-même de porter atteinte à la LCI ». Le gestionnaire du domaine n'a pas à respecter la LCI et peut y porter atteinte. Car la gestion du domaine était justifiée par l'IG qui est un vrai ppe faisant que le gestionnaire du domaine n'a jamais l'obligation d'accorder une autorisation pour l'occupation du domaine public. D'ailleurs, les autorisations d'occupation du domaine public sont précaires et révocables cad que le gestionnaire peut mettre fin à l'autorisation en vertu de l'IG.

Paragraphe 2 : la liberté d'entreprendre

Elle a été consacrée de manière ambiguë → elle a été consacré par le CC en 1982, dans sa décision loi de nationalisation. La liberté qui au terme de l'article 4 de la DDHC.

En 1982, le juge dégage un principe fondé sur aucun texte → va arriver la discussion sur le gouvernement des juges

À cette époque cette consécration était controversée car consécration d'un PRFRL en 1982 de liberté d'entreprendre mais fondé sur aucun texte. L'article 4 DDHC consacre la liberté en général mais non celle d'entreprendre.

Discussion qui va conduire à une opposition en doctrine :

Savy critiquait le fait que la liberté d'entreprendre ne soit fondé sur aucun texte → le constituant n'a pas consacré cette liberté alors même qu'il avait tout le loisir à le même faire. Savy y voit donc un gouvernement des juges, à savoir des juges qui viennent faire œuvre de juriste-lateur.

A travers les débats de la DDHC, la question de la liberté économique.

La liberté d'entreprendre garantit d'abord la liberté d'accéder à un marché et le libre exercice de l'activité économique sur le marché.

Il existe une liberté d'entreprendre en DUE → la liberté d'entreprendre en DUE est presque similaire à la liberté d'entreprendre mais est un peu plus vaste → la liberté d'entreprendre conventionnelle garantit elle aussi les 2 libertés vu avant, mais aussi la liberté de la libre concurrence → contrairement au droit interne, où la liberté d'entreprendre n'intègre pas la libre concurrence → cette dernière est distincte.

La pratique de la liberté d'entreprendre devant le CC° → bcp de QPC ont été posés dans le but d'invalider certaines lois en matière économiques. Les requérants sont soit des opérateurs économiques ou des fédérations d'opérateur économique. Ils ont des moyens qui leur permettent d'aller devant le CC°.

Pratique de la liberté d'entreprendre devant le juge constitutionnel : énormément de recours QPC en matière économique et notamment dans le but de faire invalider des lois en matière économique notamment entre 2012 et 2018. Ce sont souvent des requérants qui sont des opérateurs économiques ou des fédérations d'opérateurs économiques qui ont des moyens importants. Cela montre que la QPC ouvre le prétoire constitutionnel à ces opérateurs économiques qui ne pouvaient pas auparavant saisir le juge constitutionnel.

Il y a eu une nouvelle activité avec la QPC qui s'est développée. Avant la QPC les opérateurs ne pouvaient pas saisir directement le Conseil constitutionnel.

A) Le champ d'application étendue de la liberté d'entreprendre

Le conseil constitutionnel depuis la QPC a accru la signification de cette liberté d'entreprendre. Elle garantit l'accès au marché.

Exemple : contrôle d'une loi qui instaurait une autorisation législative pour accéder au marché.

Le conseil contrôle aussi l'exercice de l'activité économique = il vérifie si les lois ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre. C'est sur ce fondement que le juge peut contrôler les lois relatives à la fermeture hebdomadaire des commerces, une loi qui vient encadrer certaines activités particulières.

La liberté d'entreprendre a été quelque peu étendue par le conseil constit depuis la QPC, elle n'englobe tjrs pas la libre concurrence (= qui n'a pas de valeur constitutionnelle). Ceci étant, depuis 15 ans on trouve des décisions fondées sur la liberté d'entreprendre et qui pourtant ne protègent pas seulement l'accès ou le libre exercice de l'activité économique.

Exemple : Le Conseil peut contrôler une loi instaurant un monopole au regard de la liberté d'entreprendre, c'est un contrôle de légalité concurrence. En DUE, le contrôle du monopole relève du contrôle de la libre concurrence. Ainsi, le conseil ici étend la liberté d'entreprendre (= CC, QPC, 2010, monopole sur les courses hippiques).

Le Conseil contrôle aussi les législations qui viennent restreindre la liberté des prix (= CC, QPC, 2013, prix du tabac dans les doms). La liberté des prix est liée à la question de la concurrence. En d'autres termes, le Conseil garantit la libre concurrence sur le marché de manière implicite.

Le conseil a contrôlé au regard de la liberté d'entreprendre une loi qui a opéré une délégation de réglementation à un opérateur privé : le Conseil considère que cela est contraire à la liberté d'entreprendre.

Hypothèse dans laquelle la loi confie à un régulateur privé d'un marché de réguler le marché = en droit de la concurrence cela est une pratique anticoncurrentielle, c'est un abus de position dominante qui est prohibée par ppe. Par conséquent, le Conseil va protéger la concurrence sur le marché par le prisme de la liberté d'entreprendre.

= CC, QPC, 2010, nom de domaine internet.

B) Contrôle restreint de la liberté d'entreprendre

Ce contrôle a progressé mais est restreint.

1) L'évolution du contrôle de la liberté d'entreprendre

Ce contrôle par le juge constit est limité dans ses premières décisions : la doctrine dit que c'est un contrôle platonique. EN 1982, le conseil interdit que les limitations arbitraires et abusifs. A contrario en 1982, il est possible de la restreindre si ce n'est pas abusif ou arbitraire. En 1982 le Conseil va prendre une décision encore plus radicale : CC, 1982, audiovisuelle (= tant qu'une loi n'intervient pas, cette liberté n'existerait pas).

Pendant près de 20 ans le Conseil ne va censurer aucun texte sur le fondement de la liberté d'entreprendre.

2000 : 1^{ère} censure : CC, 13 janvier 2000, réduction du temps de travail.

2001 : contrôle de proportionnalité sur les atteintes à la liberté d'entreprendre.

= CC, 2001, archéologie préventive : cela implique de vérifier la justification de l'atteinte à la liberté (motif d'IG) et la proportion de la mesure. Ceci étant, il y a une subtilité, ce contrôle est dit de la **disproportion manifeste** cad qu'il est restreint à l'erreur manifeste d'appréciation du législateur.

Le juge fait progresser son contrôle d'un p.d.v. de la méthode.

2) La limitation du contrôle de la liberté d'entreprendre

Le degré de contrôle du juge est limité.

1^{ère} difficulté : les méthodes du juge constitutionnel. Le juge n'a jamais recours à l'analyse économique.

a) La limitation du degré de contrôle du juge

Le contrôle du juge est nécessairement un contrôle de proportionnalité (de la disproportion manifeste) depuis 2001 et cela implique du juge d'effectuer un examen de la justification de l'atteinte par l'IG, un contrôle de l'adéquation de l'atteinte et enfin le contrôle de la disproportion manifeste.

Ces trois contrôles sont effectués de manière variable et assez limitée.

Le contrôle de la justification : le Conseil n'a jamais censuré un texte pour absence de justification dès lors qu'il se réfère à la justification du législateur lui-même. En d'autres termes, il ne contrôle jamais effectivement la justification de l'atteinte de la liberté d'entreprendre.

Le contrôle de l'adéquation de l'atteinte : Ce contrôle n'est jamais effectué par le CC. Le CC confond cette étape avec l'étape relative à la proportion. Il est assez lacunaire sur cette étape du contrôle.

Le contrôle de la disproportion manifeste : les décisions sont très variables. Bcp de décisions dans lesquelles le CC va dire simplement que la mesure n'est pas disproportionnée (= ramène à ne rien faire).

Ainsi, c'est un contrôle pas suffisant et d'un p.d.v. général, le CC fait ce qu'il veut, s'il veut vraiment contrôler la loi, il a les moyens de le faire et l'inverse est aussi possible et faisable.

Exemple : il y a quelques années, volonté de protéger les personnes prostituées et donc de faire lutter cette profession mais pas possible de la rendre illégale en vertu de la libre-exercice de l'activité. Ainsi, on vient pénaliser les clients de prostitué. Le CC devait vérifier si une telle loi est conforme à la liberté d'entreprendre. Le CC a validé ce texte mais la difficulté ce n'est pas la validation mais le raisonnement du CC. Le CC recopie ce qu'a dit le législateur : lutter contre la prostitution. Concernant, l'adéquation, le CC n'a pas effectué ce contrôle. La mesure n'a rien d'adéquante et le CC n'a pas contrôlé cette adéquation ni la proportion.

Le CC ne contrôle rien dans cette décision. Il n'y a pas de contrôle d'adéquation, de proportion et de justification.

La prostitution a progressé depuis cette loi.

Le CC rend des décisions discutables.

Explication : Le CC en réalité ne veut pas limiter les politiques publiques en matière économique et il ne souhaite pas avoir une j.p. politique, qui fermerait la porte à certaine politique publique.

Exemple : En 1982, le CC accepte le concept de nationalisation et en 1986 il accepte le p.p.e. de privatisation.

= le CC valide les deux techniques à l'idée qu'il ne veut pas fermer la porte à une idée politique (gauche ou droite).

Dans d'autres décisions, le même CC a validé l'ouverture à la concurrence des secteurs du jeu du hasard alors qu'il y avait accordé un monopole cela montre que le CC n'a pas de politique économique déterminé en j.p.

Ce contrôle est donc trop restreint mais s'explique par le fait de ne pas empiéter dans les libertés politiques.

b) L'insuffisance des méthodes de contrôle

Le juge n'a jamais recours à l'analyse économique qui permet d'évaluer l'impact d'une réglementation ou d'une législation sur le fonctionnement d'un marché. C'est une méthode utilisée en droit de la concurrence et cela s'effectue sur un marché déterminé (= lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un produit déterminé, sur un territoire géographique déterminé et à destination de personne particulière). Le CC ne délimite jamais de marché pertinent.

Cette absence de délimitation l'entraîne à rendre des décisions insuffisantes : CC, QPC, 2011, Somodia

= à propos du repos le dimanche en Alsace. C'est une décision qui vient consacrer un PRFRL de l'existence du droit local d'Alsace Moselle. C'est une décision qui intervient dans un cadre juridique particulier (= droit local allemand de l'Alsace Moselle). Ici un texte législatif de droit local était en cause (fermeture des commerces le dimanche) le CC a validé ce texte en considérant qu'il permettait de préserver l'égal concurrence entre les opérateurs alsaciens et ceux du reste de la France. En l'espèce le marché pertinent à prendre en compte c'était le marché de la consommation de certains produits en Alsace mais pas l'ensemble du territoire national. Donc tous les usagers sont allés en Allemagne. Cette décision va à l'encontre de la concurrence entre alsacien et allemand.

Autre illustration : CC, 2019, loi pacte : privatisation de l'aéroport de Paris et la française des jeux

= le CC doit contrôler les privatisations au regard de l'alinéa 9 du préambule de 1946 et selon cet alinéa ne sont pas privatisables les monopoles de fait et SP nationaux. En d'autres termes il devait contrôler si l'aéroport de Paris constituait un monopole de fait ou un SP national.

Le CC n'a jamais identifié de monopole de fait depuis son existence cad qu'il a tjrs autorisé les autorisations de privatisation. En l'espèce il va considérer que ce n'est pas un monopole de fait donc est privatisable.

Le raisonnement du CC : il ne s'est fondé ici sur un mauvais marché pertinent. D'un p.d.v. économique il y a un monopole de fait (les vols internationaux aéroportuaires). Et pourtant le CC va dire que l'aéroport de Paris est en concurrence avec le ferroviaire sur des transports internationaux (disponibles dans toutes les autres villes de France) donc pas de monopole de fait. Le CC va plus loin en considérant que l'aéroport de Paris est en concurrence avec d'autres plateformes aéroportuaires européennes pour les vols internationaux. Le marché pertinent en l'espèce c'est le marché national des vols internationaux or le CC se base sur le marché européen. Le CC étend le plus possible le marché pertinent et moins il est possible de constater un monopole de fait de l'aéroport de Paris.

= ainsi il considère qu'il n'y a pas de monopole de fait donc possibilité de privatiser.

Pour la française des jeux : elle a un monopole de fait et de droit. Le monopole existe concernant la française des jeux mais le CC vient dire que le monopole de droit n'est pas un monopole de fait et qu'il n'y a pas de monopole de fait donc possibilité de privatisation.

La question de la légitimité du CC revient souvent. Le CC n'a pas une existence qui est garantie dans les années qui viennent. Le CC est essentiel à la démocratie en revanche, il faut un meilleur juge constitutionnel (comme en Italie ou en Allemagne).

Chapitre 2 : Le principe de non-concurrence entre opérateur public et privé

Ce principe est un des corollaires de la LCI, c'est une conséquence de celle-ci, elle a une signification assez radicale car selon ce principe, en principe, une PPB ne peut pas exercer une activité économique.

→ les activités industrielles et commerciales sont réserver secteur privé, car une PPB dispose de moyen presque illimité, les PPB ne peuvent pas faire faillite.

Ceci étant, ce principe s'est tjr mal accommodé d'une réalité très différente → on a constater très rapidement que la PPB prenait en charge des activité économique, la plupart du temps dans le cadre de l'IG ; progressivement, le juge a assoupli ce principe

Ce principe a été réaffirmé récemment, mais le juge a admis plus facilement des des dérogations à celui-ci

Section 1. L'évolution historique du principe de non-concurrence

Paragraphe 1 : l'origine de ce principe

Consacré dans un **arrêt de 1901 du CE → Casanova**. En 1901, le CE considère qu'une PPB ne peut exercer une activité économique que dans des circonstances exceptionnelles → sinon elles sont réservées à l'initiative privée.

On est dans une époque où la pensée libérale est dominante.

Dès les années 1920, on s'est rendu compte que la pratique administrative était très différente → dès les années 20/30 on a vu apparaître le socialisme municipal, avec le conteste de crise économique qui a entraîné une hausse des prix.

Durant cette époque, des communes ont pris en charge des activités commerciales pour lutter contre les hausses de prix.

La pratique se révèle très différente de la décision de 1901, et le CE va prononcer un premier assouplissement de celle-ci dans un arrêt du 1930, chambre syndicale du commerce en détail de la ville de Nevers (arrêt Nevers) → le juge commence d'abord par réaffirmer la LCI et va réaffirmer le principe de non-concurrence → Mais le juge va apporter une énorme dérogation à ce principe

Il va autoriser à la PPB d'intervenir dans le domaine économique sous 2 conditions :

- Il faut que l'activité soit d'intérêt général, d'intérêt public
- Et puis, le juge va exiger des circonstances particulières de temps et de lieu → cela renvoie à une carence de l'initiative privée → cad dans le cas où il n'y a aucun opérateur privé sur le marché

Cet arrêt de principe va rester dans le droit positif pendant 76 ans, le juge n'a eu de cesse que d'assouplir la mise en œuvre de cette solution. Tout au long du XXe siècle, le juge a apprécié souplement cette jp Nevers.

Paragraphe 2 : L'application souple de la JP Nevers

Suite à cet arrêt, le CE a rendu plusieurs décisions qui témoignent d'une appréciation très souple de ce principe de non-concurrence → le CE a retenu le concept de carence qualitative de l'initiative privée

- En 1930, quand le juge parle de carence, on pense plutôt à une carence quantitative, cad qu'il n'y a pas d'opérateur sur le marché en question. Mais dans les années 60, le CE va prendre en compte cette idée de carence qualitative → l'idée qu'il y a des opérateurs sur le marché, qu'il existe une offre privée' mais qui est qualitativement insuffisante → la qualité peut s'assimiler au tarif de la prestation.
Consacre cette idée de carence qualitative → **Arrêt 1964, Ville de Nanterre** → le CE va admettre une carence qualitative de dentaire à Nanterre, il n'existait pas d'offre de dentaire gratuit et il y avait, par conséquent, une carence qualitative de l'initiative privée.
Dès lors que le service est proposé gratuitement, dès lors qu'il est social, le juge admet très facilement sa création.

Cette solution est tjr valable en droit positif mais elle ne serait pas la même aujourd'hui → À l'époque nanterre était un terrain de nombreux bidonvilles et pour cela il était nécessaire d'offrir aux gens un service gratuit de ce genre

Le juge est allé plus loin et dans certaines hypothèses il n'a pas exigé de carence pour admettre l'exercice d'une activité économique par la PPB :

- Le CE a admis l'auto-prestation ; c'est l'idée qu'une PPB exerce une activité économique dans le but de servir une autre PPB. C'est par exemple le cas d'une boulangerie militaire qui viendrait fournir du pain à des prisons, qui est jugé comme une auto-prestation jugé sans conditions (**1970, CE section, arrêt uni pain**).
- Deuxième hypothèse → **Arrêt 1959, CE, décision Delansorne** : le juge l'a admis en matière d'extension de service existant. Le juge a admis que l'on puisse étendre un service déjà existant dans 2 conditions :
 - Il faut que la nouvelle activité soit connexe à l'activité initiale
 - La nouvelle activité soit profitable à l'utilisateur du serviceSi ces 2 conditions sont remplies, cette nouvelle activité peut être créée librement.

Cette évolution a conduit la doctrine à s'interroger sur le fait que le juge a abandonné le principe de non concurrence

Paragraphe 3 : la remise en cause doctrinale du principe de non-concurrence

Il y a plus de 25 ans, la doctrine s'est demandé si le juge n'avait pas abandonné ce principe et si il ne l'avait pas transformé dans un principe d'égal concurrence entre la PPB et la PPV, notamment dans l'accès au marché → principe selon lequel toute personne peut exercer une activité économique

Cette position doctrinale était fondée sur plusieurs considérations → notamment le DUE qui est indifférent à l'égard de la nature publique ou privée d'un opérateur → **Article 345 TFUE**.

Le DUE ne différencie pas le régime applicable entre le PPB et le PPV.

Surtout, le CE a rendu des décisions étonnantes depuis la fin du XXème siècle → **avis de section, 2000 du CE, Jean-Louis Bernard consultant** : le CE dit « qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit à une PPB de candidater à l'attribution d'un contrat public ».

Quand on lit les conclusions que tous les acteurs privés et publics peuvent accéder au marché → cette lecture s'est révélée erronée par la suite, car la formule de Catherine, comme les autres membres de la doctrine qui ont commenté l'avis, il y a une confusion entre la création de l'activité économique et la candidature à un contrat public pour la PPB (qui impose nécessairement que l'activité économique ait été créée au préalable). L'avis dit que la candidature est libre, mais le CE ne dit à aucun moment que la PPB ne peut créer une activité économique → cette création est tjr soumise à la liberté du commerce et de l'industrie

Tjrs pas après cette avis d'égal concurrence entre les PPB et PPV

Section 2. La portée contemporaine du principe de non concurrence

ce principe de non-concurrence a été **reformulée par le CE en 2006, OABP** : le CE va d'abord rappelé ce principe de non-concurrence → le fait que les activités économiques sont réservées à l'initiative privée.

Mais le CE va encore assouplir les conditions de création d'une activité économique.

Le CE va s'interroger sur le régime applicable à la PPB une fois l'activité privée → il considère que cette opératrice publique va être soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés. C'est une idée d'égal concurrence sur le marché entre opérateur PB et PV.

Tjr pas d'égal concurrence dans l'accès au marché, mais il y a une égale concurrence dans le marché.

3 remarques :

- Cette décision concerne l'ensemble des PPB, y compris l'État → L'arrêt Nevers ne concernait que les collectivités territoriales à l'époque
- Le juge va parler pour la première fois d'activité économique de la PPB, et non plus seulement d'activité industrielle et commerciale de la PPB → ce changement de terminologie n'est pas anodin, la notion d'activité économique détermine le champ d'application des règles de concurrence. C'est donc pour cette raison que le CE retient ces termes
- Était en cause en 2006 la mission d'appui au contrat de partenariat ; c'était un service de l'État qui avait pour fonction de donner des conseils juridiques aux collectivités en matière de passation de contrat de partenariat. → Les avocats considéraient que l'État avait créé une activité économique par le biais de cette mission

Paragraphe 1 : l'assouplissement du principe de l'intervention publique sur le marché

Dans cette décision, le juge va modifier les conditions de création d'une AC par la personne publique, le juge va assouplir les conditions d'intervention de la PPB.

Le juge va d'abord faire des rappels sur la liberté d'exercer par la PPB des activités non économiques et les conditions de cette activité

A. La liberté d'exercice pour la PPB des activités non économiques

La LCI ne s'applique que pour la création d'activité économique → pour la création des activités non économiques, la LCI ne s'applique pas.

Quand la liberté est exercée sur quelque chose qui n'est pas un marché, le juge considère que la PPB peut en créer librement.

Le CE va, dans un premier temps, que n'est pas économique l'activité nécessaire à la réalisation de mission de SP.

- En d'autres termes, ces activités nécessaires à la réalisation de mission de SP peuvent être créées librement par la PPB.

Mais qu'est-ce que ce genre d'activité ?

Le CE s'est prononcé dans l'OABP, il va considérer que la mission d'appui dont on a parlé n'était pas une Activité économique mais une activité nécessaire au SP.

Le juge va aller plus loin en **2011, dans un arrêt d'assemblée, décision association pour la promotion de l'image**. → à propos de la prise de photographie des demandeurs de passeport en préfecture. → on va admettre que la préfecture puisse prendre elle-même la photo des demandeurs de passeport, ce qui a causé un préjudice pour les photomaton.

Le CE a validé le fait que les préfectures puissent prendre en photo les demandeurs de passeport → car c'est une activité nécessaire à la réalisation de mission de SP

Arrêt Sigmalis 2014 → Le juge devait se prononcer à propos d'un site Internet public qui publiait les prix de vente de l'essence. Selon le juge, ce site peut être créé librement par l'État dès lors qu'il ne s'agit pas d'une AC mais d'une activité nécessaire au SP.

Le dernier arrêt du CE qui s'est prononcé sur cette question est l'arrêt *Ordre des avocats* de 2007, à propos de la création d'un médiateur des entreprises. C'est selon le juge une activité non économiques

Ces solutions sont très souples pour la PPB, ces solutions vont un peu trop loin ; d'un point de vue juridique, on peut s'étonner de ces décisions. Si on lit le CE, on peut comprendre que dès lors qu'est en cause un SP on peut librement créer une activité. Mais la difficulté est que cette solution n'est pas compatible avec le DUE, et à l'inverse en DUE un SP peut être qualifié d'AC → dès lors que le SP est qualifié

d'AC, le SP est soumis aux règles de droit du marché, cette activité ne peut donc pas être créée librement.

La solution du CE reste assez éloignée de celle du juge européen. En DUE, dès lors qu'est en cause un SP économique, on ne peut pas le créer librement.

B. Les conditions de création des activités économiques par la PPB

Ces conditions vont être assouplies en 2006. La première condition est celle qui se réfère à la compétence de la PPB → est-ce que la PPB en cause est compétente pour créer une AC ? → Concernant les collectivités, ce qui va justifier leur compétence est la notion d'intérêt public local → la commune est compétente pour toute question d'intérêt public local.

Concernant les établissements publics, leur compétence est délimitée par le principe de spécialité des établissements publics → cette compétence est limitée par les textes qui les instituent.

Le CE va surtout se prononcer sur la LCI. Il va commencer par rappeler le principe de non-concurrence, il rappelle cette idée suivant laquelle les AC sont réservées à l'initiative privée.

Le CE en nous rappelant ce principe nous dit qu'il n'existe pas d'égal concurrence dans l'accès au marché.

Le juge maintient ce principe de non concurrence, mais il va surtout assouplir les dérogations à ce principe, il va assouplir les conditions pour créer une AC.

En 2006, le juge n'exige plus qu'une seule condition pour que la PPB crée une AC → la condition d'intérêt public. → « L'intérêt public qui peut notamment résulter de la carence de l'initiative privée ».

Il faut déduire de cette formule qu'il n'y a plus qu'une seule condition pour que la PPB intervienne sur le marché ; et aussi que cette condition de la carence de l'initiative privée n'est plus une condition autonome, elle n'est plus systématiquement exigée, mais qu'elle peut révéler simplement l'intérêt public qui permet à la PPB de créer cette activité.

Non seulement le juge assouplit les 2 conditions retenues en 1930, mais le juge va apprécier souplement l'intérêt public.

D'abord, le CE accepte tjr de prendre en compte la carence qualitative de l'initiative privée qui révèle tjr la possibilité pour la PPB de créer une AC.

→ On voit cela dans la première application de l'arrêt OAPB, dans la **décision de département de la Corrèze en 2010**, à propos de la création d'un service de télé assistance à domicile pour les personnes âgées créés par un département.

Le département de la Corrèze a fourni ce service à un prix très inférieur au marché → comme dans l'arrêt Ville de Nanterre, le juge va considérer qu'il y avait une

carence qualitative de l'initiative privée et qui va donc révéler l'intérêt public → il n'existait aucun opérateur sur le marché qui fournissait le service à un tel prix

Ce n'est pas tant la nature de l'activité → ce qui est pris en compte ici c'est le tarif de l'activité, le fait que l'activité est fournie à un tarif social qui vient révéler la carence qualitative de l'initiative privée.

Cette JP signifie que dès lors que le service est fourni pour des motifs sociaux, sa création est quasiment libre pour les PPB.

Le juge prend en compte l'intérêt public (IP), mais aussi le caractère local de l'IP → le CE va considérer que l'intérêt public local peut être extraterritorial, il peut exister au-delà des limites de la collectivité.

Un intérêt public local extraterritoriale permet au juge qu'une PPB crée une AC afin de candidater à un contrat public sur un autre territoire. → par exemple, en matière portuaire, il y a des départements qui gère les ports d'autres département, on va admettre que certain département crée une AC pour pouvoir faire un contrat de cession de gestion des ports avec un autre département → **arrêt 2009, département de l'Aine**

2 remarques sur l'assouplissement :

- Cette solution n'est pas celle du DUE. Le DUE exerce un contrôle sur la réalisation de service d'intérêt économique général et le juge de l'UE exerce un contrôle de la création d'un SIEG. → Le juge de l'UE exige une carence du marché pour créer le SIEG, systématiquement exigé par le juge de l'Union → selon un juge de l'ancien **TPICE, en 2005 décision Fred Olsen**.
- En tout état de cause, la loi peut renforcer les conditions de l'intervention de la PPB sur le marché et des textes législatifs spéciaux peuvent exiger une carence pour autoriser la création d'une AC par la PPB → exemple : les maisons de SP en milieu rural créés par la loi de 2015, et la loi vient subordonner cette création à l'inadaptation des offres privées.

Dans cette décision le juge renforce les modalités de l'intervention de la PPB

Paragraphe 2 : Le renforcement des modalités de l'intervention de la PPB sur le marché

Tjr pas d'égal concurrence dans la création d'AC

Le juge va poser une égale concurrence entre les PPV et les PPB sur le marché → le juge va exiger que l'AC soit exercé dans les mêmes conditions que les opérateurs privés, et notamment que l'AC soit exercé dans les mêmes conditions concurrentielles que la PPV

Cette égale concurrence dans le marché avait déjà été posée par l'avis du CE 2000 vu supra

Arrêt OABP → La PPB doit respecter les règles de concurrence dès lors qu'elle exerce une AC

Cette règle est logique car la PPB exerce une AC → dès lors, elle est soumise aux règles de concurrence qui s'appliquent à l'exercice d'AC.

Cette soumission de la PPB à ces règles n'a rien de surprenant.

Mais comment le juge va contrôler cet égale concurrence → le juge exerce 3 contrôles :

- Le prix proposé par la PPB
- Il va contrôler si l'opérateur public n'a pas bénéficié d'avantages liés à sa mission de SP
- Le juge va exiger une comptabilité analytique qui permet de contrôler les éléments précédents

A. Le prix proposé par l'opérateur public

Il doit être supérieur au coût supporté par l'opérateur → il ne peut pas être inférieur au coût dépensé par l'opérateur dans le cadre de l'exercice de l'AC.

Ce principe d'infériorité du prix par rapport au coût est appelé le prix prédateur → le prix prédateur qui permet d'éliminer les concurrents du marché est interdit.

Le juge va vérifier le coût et les prix proposés par l'opérateur public → pas de prix prédateur possible.

La question va se poser pour la PPB qui exerce à la fois des activités concurrentielles mais également des activités de SP.

Quels coûts faut-il prendre en compte ?

Cette question s'est posée dans l'affaire des vedettes vendéennes, celle-ci exercent des missions de SP. Cette compagnie assure également des services touristiques. Pour accéder à ces bateaux il faut utiliser un ponton et celui-ci est le même pour se rendre au SP que pour les missions touristiques → prend-on en compte le coût du ponton ?

Il faut prendre en compte le coût incrémental, il inclut l'ensemble des dépenses sauf celles liées au SP. Dans cette affaire, on ne prend donc pas en compte le coût du ponton. → **Commission européenne 2001, affaire Deutch post.**

B. Le contrôle du juge sur l'absence d'avantage découlant de sa mission de SP

Le juge va vérifier si l'opérateur n'a pas bénéficié d'avantages liés à sa mission de SP afin de favoriser son activité concurrentielle

→ Utiliser des ressources de SP pour favoriser son activité concurrentielle est une subvention croisée qui est une pratique anticoncurrentielle prohibée. → c'est l'idée d'utiliser des ressources de monopoles pour favoriser une activité concurrentielle

Cette question s'est posée pour les bureaux de poste → la poste opère des activités concurrentielles.

La poste est aussi une banque. → On se demandait si le fait que le même guichet faisait la mission du SP et l'activité concurrentielle, ne constituait pas une subvention

croisée → les avantages du SP peuvent profiter à l'activité concurrentielle → on a dit que c'était une subvention croisée est aujourd'hui il y a 2 guichets

C. Contrôle des opérations comptables

Oblige l'opérateur communique systématiquement ses comptabilités analytiques qui permet de vérifier les coûts et les éventuels avantages de l'opérateur.

Le CE considère que l'absence de production de comptabilité révèle une violation du principe de l'égal concurrence → si l'opérateur public ne produit pas cette comptabilité, il sera sanctionné.

Paragraphe 3 : candidature de la PPB à un contrat de la PPB

→ situation dans laquelle l'activité économique a déjà été créée, la question qui se pose est de savoir si la PPB opérateur économique peut candidater à un contrat de la commande publique sur un autre territoire.

→ le CE a apporté une question explicite sur ce point. Dans l'avis Bernard consultant, le juge admet cette candidature → il dit qu'aucun texte ni aucun principe pose l'interdiction pour la PPB de candidater à l'attribution d'un contrat public

En 2009, le CE va rendre l'arrêt département de l'Aine → le juge se prononce sur le point de savoir si la PPB peut librement candidater à un CP ou si elle doit démontrer un intérêt public local au moment de la candidature. En substance, le juge considère que la PPB n'a pas démontré d'intérêt public pour candidater, elle peut librement candidater une fois qu'elle a créé l'activité économique.

Cette décision n'était pas la plus heureuse pour la raison suivante : le problème est que quand on crée une AC, il n'y a pas de contrôle sur cette AC. L'intérêt de demander l'intérêt public est de contrôler

C'est en raison de cette faiblesse que le CE a encore évolué dans un arrêt d'assemblée de 2014, décision Armor SNC → exige un intérêt public local pour que la PPB candidate à l'attribution d'un CP. → Conditionné à la démonstration d'un IP local.

Le juge va identifier l'IP local qui justifie cette candidature, le CE va conditionner cette candidature à 2 conditions pour que celle-ci révèle un IP local :

- Il faut que la candidature constitue le prolongement normal d'une mission de SP dans l'intérêt financier de ce service → on retrouve la même formule dans l'arrêt de 1959 vu supra.
- Que la candidature ne compromette pas l'exercice de la mission de SP de l'opérateur

Chapitre 3 : Libertés économiques contemporaines

L'idée de libre concurrence renvoie à des textes que l'on a déjà vu → ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

La libre concurrence existe en outre en tant que principe général du DUE ;
précisément en tant que liberté garantie par les traités.

On trouve très clairement dans le droit positif cette notion de non-concurrence. Le CE avait déjà dégagé un PGD du droit de la concurrence qui a été invoqué pour la première fois dans l'avis Bernard consultant.

Jusqu'à présent, on a qualifié des libertés qui sont toutes qualifiées de droit subjectif, de droit qui appartient à une personne → liberté d'entreprendre est le droit pour une personne morale de créer une AC par exemple.

La liberté de la concurrence n'est pas un droit subjectif des administrés et des opérateurs économiques → cette liberté protège le marché, elle va garantir le fonctionnement concurrentiel d'un marché.

C'est pour cette raison en particulier que l'on ne peut pas invoquer cette liberté en référé liberté.

La liberté de la concurrence n'a pas de valeur constitutionnelle en droit français.

Qu'est ce qu'implique la liberté de concurrence en D français.

Concernant les PPB, la libre concurrence a 2 implications :

- La PPB doit respecter les règles de concurrence dès lors qu'elle exerce une activité économique. Dans ce cas-là, la PPB sera soumise au même régime que les opérateurs privés.
- Elle a aussi une 2^{ème} conséquence : elle tient à ce que les règles de concurrence sont, non pas applicables, mais opposables aux actes de puissance publique. Cela signifie qu'un acte administratif ne peut pas avoir pour effet de placer un opérateur en situation anticoncurrentielle. → Cette opposabilité des règles de concurrence aux actes administratifs a été admise dans une grande décision de **1997 du CE, arrêt de section Million et Marais**. Première décision dans laquelle le CE va opposer les règles de concurrence à un contrat administratif → il était allégué que la durée du contrat était excessive et que cela plaçait le concessionnaire en position dominante. Le CE va rejeter l'argument mais va opposer les règles de concurrence au contrat, mais en précisant que la durée du contrat ne plaçait pas le concessionnaire en position dominante.

Les règles de concurrence sont opposables à la PPB → cette décision a choqué car les règles de concurrence s'appliquent originellement aux opérateurs économiques, aux opérateurs économiques privés mais pas à l'origine des règles conçues pour la PPV.

Il y a près de 20 ans, il y avait une discussion suivant laquelle il était intolérable que la PPB soit soumise aux règles de la concurrence → car elle représente l'intérêt général.

Il faut nuancer cette critique pour plusieurs raisons :

- Juridiquement, même s'il choisit de droit privé, ce droit est tjr opposable à la PPB et un acte administratif ne peut jamais une PPV dans une situation de violer le droit privé → l'opposabilité des règles de droit pénal à la PPB résulte d'un arrêt de **1996 du CE, arrêt société Lambda**. La décision de 1997 est donc le prolongement de ce principe qui interdit un acte administratif de placer un opérateur en situation de violer le droit privé.
- On ne peut pas opposer de manière manichéenne d'une part l'intérêt général et d'autre part la concurrence → la concurrence est aussi un élément de l'intérêt général qui doit être concilié avec les autres impératifs de l'intérêt général. La concurrence comme élément de l'intérêt général doit être concilié avec d'autres éléments de l'intérêt général

Le principe de la soumission des actes administratifs aux règles de concurrence → ensuite on se demandera comment un acte administratif respecte ces règles et dans un troisième temps on parlera du contentieux administratif de la concurrence

Section 1. La soumission des actes de puissance public aux règles de concurrence

Il est certain que tous les actes administratifs se voient opposer les règles de concurrence.

Le juge admet qu'il est possible de déroger à ces règles de concurrences dans l'intérêt général

Paragraphe 1 : la soumission de l'ensemble des actes administratifs aux règles de concurrence

Décision du juge des conflits 1989 Saede : dans cette décision le juge des conflits va reconnaître la compétence exclusive du juge administratif pour contrôler un acte de puissance publique au regard des règles de concurrence
 Cette décision avait une conséquence sur le fon car le juge des conflits admettaient des actes administratifs devaient respecter les règles de concurrence.

Le CE a mis du temps pour aboutir à cette solution.

Cette solution opère une répartition des compétences : les activités éco sont contrôlées par l'ancien conseil de la concurrence. A l'inverse le juge administratif redevient compétent en matière d'acte de puissance publique dès lors qu'est en vause un acte de PPB.

Cela paraissait clair en 1989, mais dans un premier temps le CE va refuser d'appliquer les règles de concurrence aux actes administratifs avec des justifications étonnantes.

En 1993, le juge considère qu'un acte administratif n'est pas susceptible de fausser le jeu de la concurrence

Pourtant c'était la solution du DUE qui avait déjà accepté de soumettre des actes de la puissance publique aux règles de concurrence : **CJCE 1977 dans une affaire Ino contre Atab**

Le CE est revenu en 1997 dans un arrêt de principe sur sa position → depuis il a soumis tous les actes administratifs aux règles de concurrence.

Tout d'abord, le juge a opposé les règles de concurrence aux actes d'organisation du SP → **Section 1998 affaire UHP**

→ Décision étendue aux actes de gestion du domaine public, → le CE l'a consacré dans un **arrêt de section de 1999, décision société Eda**.

Les actes de police administrative sont aussi soumis aux règles de concurrence → jugé à 2 reprises par le CE d'abord dans un avis de section de 2000 du CE, avis L et P publicité ; confirmé par un **arrêt de 2009, décision compagnie des bateaux mouches**.

Le juge a opposé les règles de concurrence aux actes d'autorisation administrative → le CE l'a imposé dans un **arrêt de section 2006, décision commune de Houlgate**.

Les actes administratifs se voient opposer les règles de concurrence, cad que l'acte administratif ne peut pas placer un opérateur en situation de violer ces règles. Mais l'opposabilité n'est pas une applicabilité → ces règles ne sont pas applicables au SP, aux actes des SP, l'applicabilité concerne exclusivement les activités économiques. Une activité éco se voit appliquer les règles de concurrence en revanche les actes administratifs ne se voient pas appliquer ces règles mais celles-ci lui sont opposables

La question est de savoir quelles sont les règles de concurrence opposables aux actes admin

→ Ce sont essentiellement des règles du Code de commerce : L420-1 et L420-2 →

Ce sont des règles qui devraient prendre en compte le juge → le JA a du mal à manier ces règles. Les règles de concurrence impliquent une analyse économique particulière à savoir que pour évaluer une pratique concurrentielle il faut :

- Déterminer un marché pertinent
- Déterminer la position dominante de l'opérateur sur le marché (pour les abus de position dominante)
- Révéler la pratique d'abus de position dominante

Le CE avait du mal à délimiter le marché pertinent et à qualifier les pratiques de pratiques anticoncurrentielles.

Il a d'abord formulé des demandes d'avis au conseil de la concurrence, ce qui permettait d'analyser le marché, puis il s'est progressivement accommodé en matière de raisonnement économique → il s'est converti à l'analyse économique du droit de la concurrence.

Ceci-étend, le JA quand il le peut va préférer éviter de mettre en œuvre les règles de concurrence, le juge va dans certaines affaires se référer à d'autres normes qui ont peut-être les mêmes conséquences mais qui sont plus faciles à manier pour le juge → au principe d'égalité par exemple, qui peut permettre de garantir l'égal

concurrence entre opérateur sur un marché → c'est peut-être plus facile de raisonner pour le JA avec ce principe que celui de non-concurrence
Cette tendance est tjr réelle, il se réfère tjr, par moment, au principe d'égalité pour ne pas avoir recours à une analyse économique détaillée

CC 1987, conseil de la concurrence → PFRLR compétence du JA → le juge administratif est compétent dès lors qu'est en jeu un acte de puissance publique

Paragraphe 2 : les dérogations aux règles de concurrence dans l'intérêt public

Ces règles de concurrence ne sont jamais absolues et doivent être conciliées avec les impératifs d'intérêt général → il est donc tjr possible pour le JA de déroger aux règles de concurrence pour des motifs d'intérêt général → cette conciliation le juge l'a admis en 2003 puis dans l'arrêt bateau mouche en 2009

En JP le juge n'a jamais admis une telle dérogation
Le juge exerce un contrôle de proportionnalité, il va regarder si l'atteinte au principe de libre concurrence n'est pas excessive → pour arriver à cette conclusion il va mettre en balance les différents intérêts en présence. Effectuer une sorte de bilan

Cette dérogation peut être prise en compte au stade des référés notamment le référé suspension (subordonné à 2 conditions : urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision) → urgence qui résulte d'une atteinte aux intérêts en présence.
Quand il apprécie l'urgence, le juge effectue une mise en balance des intérêts, un contrôle de proportionnalité ; il regarde s'il y a une atteinte aux intérêts en présence et si cette atteinte n'est pas justifiée par l'IG

CE référé 2006 POWEO : le juge va concilier l'intérêt du respect de la concurrence et les autres intérêts en présence à l'occasion de l'appréciation de l'urgence

En tout état de cause, une loi peut prévoir une telle dérogation → **CE 2009, clonique Durieux**

En doctrine, au début du XXème siècle émergeait un courant suivant lequel il existerait un droit public de la concurrence distinct du droit privé de la concurrence dont le contentieux relèverait de la seule compétence du JA. Ce droit public de la concurrence c'est l'œuvre du prof Michel Basex. La spécificité du droit public de la concurrence c'est l'existence d'une règle qui n'existe pas en droit privé de la concurrence : La dérogation des principes de D de la concurrence au nom de l'IG.

En 2025, le DPA est structuré autour de ce principe de droit de la concurrence.

Cette opposabilité va avoir une conséquence pratique puisque les administrations vont devoir respecter les règles de concurrence et ils vont devoir évaluer l'impact concurrentiel de leur norme.

Section 2. L'évaluation concurrentiel des textes normatifs

Depuis 1997 c'est une nécessité, l'autorité administrative doit vérifier si son acte ne produit pas d'effet anticoncurrentiel

→ Cette évaluation devrait être effectuée dans le cadre d'une étude d'impact mais celle-ci n'existe pas concernant les actes administratifs

→ Alors comment on procède à une telle évaluation concurrentielle ? pour ce faire, l'autorité de la concurrence a confectionné un guide en 2011 qui comprend ce que l'autorité appelle un vademecum à l'attention des agents publics qui vont identifier les hypothèses problématiques et celle où il doit avoir des attitudes particulières.

On y retrouve des recommandations, des synthèses de l'autorité de la concurrence.

Cette évaluation doit se faire en 2 temps : de manière procédurale et de manière substantielle

L'autorité de la concurrence préconise sa saisine en cas de difficulté → la façon la plus évidente d'évaluer est de la saisir pour obtenir un avis. L'autorité doit être obligatoirement consultée dans certain cas → en matière de règlement tarifaire par exemple

Au-delà de cette saisine, il y a une saisine facultative est prévue → L'autorité de la concurrence peut être saisie par le Gouv, par les collectivités territoriales ainsi que par les organisations professionnelles ou encore par la plupart des autorités de régulation ou par les juridictions

→ Cette saisie consultative peut avoir lieu pour toute question de concurrence

Dans ce cadre, l'autorité va pouvoir prendre pas mal d'avis sur la concurrence.

Depuis 2009, l'autorité de la C peut s'auto saisir, cad qu'elle peut prendre l'initiative elle-même d'étudier la concurrence, de donner un avis sur la concurrence → cette compétence est importante, elle résulte de l'article L462-4 du Code de commerce. Ce pouvoir d'avis on la qualifié d'advocaicy → l'idée qu'au travers de ses avis, l'autorité n'a que pour objectif de promouvoir la concurrence sur le marché

Analyse substantielle, analyse concurrentielle qui doit être effectué même si l'autorité n'est pas saisi → l'autorité va préconiser de suivre un questionnaire que doit se poser l'administration afin de concrètement vérifier si le texte n'a pas d'impact excessif sur la concurrence.

Ces questions peuvent être regroupées :

- Est-ce que l'activité est justifiée par l'IG ??? demander à Sée
- Est-ce que l'activité est proportionnée à son objectif, est ce qu'elle ne crée pas de distension de concurrence

Section 3. Le contentieux administratif de la concurrence

C'est avant tout un contentieux de l'annulation ; outre ce contentieux, il peut aussi être un contentieux de l'urgence.

Ce contentieux peut être un contentieux indemnitaire.

Paragraphe 1 : le contentieux de l'annulation

L'opposabilité des règles de concurrence va appeler une analyse économique particulière, qui va s'analyser en 3 temps, conformément à ce qu'impose le droit de la concurrence :

- Il va doit délimiter un marché pertinent
- Détermination de la part des marchés des opérateurs sur ce marché pertinent, et éventuellement la position dominante de l'opérateur sur le marché
- Cette analyse va conduire le juge à se demander si l'acte administratif conduit l'opérateur à abuser de cette position dominante

Au-delà de ces aspects théoriques, le juge peut avoir recours à certaines pratiques contentieuses → ce contentieux est assez localisé.

D'abord le juge peut avoir recours à des pratiques contentieuses contemporaines :

- Le juge va très doivent moduler dans le temps les effets de sa décision, cad reporter la date des faits de cette décision et prononcer une
- Le juge peut souvent faire appel à des experts dans le cadre du contentieux de la concurrence, le juge peut demander son avis à l'autorité de la concurrence
- Le juge peut aussi avoir recours à l'amicus curiae (le fait de demander leur avis à des personnes particulièrement compétentes).

Depuis 1997 et l'arrêt Million et marais il y a très peu de décision du CE dans ce domaine. Il y a très peu de décision du CE mais bcp de décisions du juge du fond.

Ce contentieux de la concurrence est un contentieux local à propos des collectivités territoriales.

Paragraphe 2 : les contentieux de l'urgence

Ces contentieux de l'urgence vont permettre aux requérants de demander au juge la suspension d'un acte qui aurait des effets anticoncurrentiels, qui doit être demandé en référé.

Quelles procédures de référé peut être pertinente pour obtenir une telle suspension ?
Le référé suspension : article L521-1 du CJA → à l'inverse le référé liberté est peu propice à une suspension en référé.

Le requérant pourra obtenir gain de cause dans le cadre d'un référé précontractuel

A. Le référé suspension

L'urgence en référé suspension s'apprécie de manière qualitative et non temporelle, au regard de l'atteinte portée aux intérêts en présence. Le requérant doit démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Le juge prend en compte les atteintes à la concurrence dans le cadre de l'urgence : le juge considère que le maintien et le développement de la concurrence constituent des intérêts publics à protéger → **Juge des référés du CE de 2004, T-online.**

Le juge va considérer que la condition d'urgence est remplie dans certain cas, en cas d'atteinte à la concurrence, mais en cas d'atteinte durable et caractérisé de la concurrence.

Caractérisé :

Le requérant doit caractériser les effets anticoncurrentiels de l'acte, le juge va devoir identifier le caractère concurrentiel de l'acte. Mais le juge des référés n'est pas un juge du fond, il doit simplement avoir un doute sur la légalité de cet acte.

En d'autres termes, pour caractériser les effets de l'acte, le juge va devoir effectuer une analyse poussée, il devrait procéder à une analyse économique.

La difficulté c'est que l'analyse heurte l'office des juges des référés qui ne sont pas censés juger du fond du litige.

Les effets doivent en outre être durables

Durable :

L'acte doit affecter durablement la structure concurrentielle du marché en cause → cela implique qu'il y ait des effets certains de l'acte. Cette recherche des effets certains de l'acte n'a rien de évident, particulièrement en matière concurrentielle
Le juge administratif va rechercher des effets certains dans le futur

Mais quand le juge apprécie l'urgence il effectue un bilan des intérêts en l'urgence et même s'il y a une atteinte à la concurrence, le juge devra mettre en balance cette atteinte avec l'intérêt public à ne pas suspendre l'acte administratif. Par conséquent, le juge pourrait décider de ne pas suspendre un acte qui porte atteinte à la concurrence au nom de l'IG.

B. Référé liberté

Article L521 :

2 conditions :

- Il faut démontrer l'urgence : s'apprécie de manière temporelle ; le juge statue dans les 48h
- Il faut démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette condition doit être remplie.

La concurrence n'est pas consacrée constitutionnellement, et il n'est donc pas possible de la qualifier de liberté fondamentale → pas possible de faire un référé liberté en matière de concurrence

C. Le référé précontractuel

C'est une procédure spécifique qui existe dans la conclusion de contrat de marché public. → Peut être mise en œuvre avant la signature du contrat

Cette procédure a un objet précis → le juge ne peut que sanctionner les règles du droit de la commande publique.

Cette procédure est évoquée aux articles L551-1 du CJA, cette procédure a pour seul objet de censurer les règles

A priori, un juge des référés précontractuel ne devrait pas se prononcer sur les effets anticoncurrentiels d'un acte administratifs.

Mais le CE a admis qu'il pouvait sanctionner la violation des règles de concurrence par la PPB, à condition que cette violation soit imputable à la PPB. Le CE l'a admis à plusieurs reprises, et notamment en 2001 → dans une décision collectivité territoriale de Corse.

Depuis 25, le juge n'a eu de cesse de faire augmenter cet office.

Paragraphe 3 : le contentieux de la responsabilité

Pourrait viser à indemniser un opérateur qui aurait subi un préjudice du fait d'un acte administratif anticoncurrentiel → on parlera nécessairement ici d'une responsabilité pour faute de la PPB, en raison de l'illégalité de l'acte en question → **arrêt du CE 1973, Driancourt**.

Il est fort probable que la faute constitue la cause directe et certaine du préjudice causé par l'opérateur. La difficulté concerne la troisième condition qui est la démonstration d'un préjudice de l'opérateur économique.

On peut avoir recours à la théorie de la perte de chance → que l'opérateur a perdu une chance soit d'aller ou de rester sur un certain marché → on évaluera le préjudice par rapport à la chance perdue.

Chapitre 4 : La liberté d'établissement et la libre prestation de service

Le droit de l'UE interdit des restrictions à la libre prestation de service et à la liberté d'établissement.

→ **49 TFUE** : consacre la liberté d'établissement et l'interdiction de restriction.

56 TFUE → interdit de restreindre la libre prestation de service

Ces libertés sont invocables par tous les opérateurs économiques aux marchés et sont invocables par tous les opérateurs économiques devant toutes les juridictions nationales.

Ces 2 libertés ne sont pas absolues, les autorités nationales peuvent y déroger sous 2 conditions :

- Elle doit démontrer la nécessité de déroger à ces libertés
- Elle doit démontrer la proportion de l'atteinte à ces libertés

Ce qui est important c'est que la justification de la restriction ne peut être fondée que sur 2 éléments : soit pour des considérations d'ordre public, soit pour des raisons impérieuses d'intérêt général qui sont identifiées par la CJUE.

Ces libertés fondamentales ont été appliquées et mises en œuvre par des actes du droit dérivé du DUE, par des directives d'harmonisation, des directives qui ont eu des conséquences assez incroyables.

Il y en a une que l'on ne peut pas ne pas connaître → directive service du 12 décembre 2006.

La directive a pour objet d'harmoniser la LPS au sein de l'UE et de supprimer les éventuels obstacles à la LPS et la LE

Cette directive s'applique au service fourni par des opérateurs ayant leur établissement au sein des EM → Ne concerne que les activités ouvertes à la concurrence, elle n'oblige pas à supprimer les monopoles.

Elle contient des exclusions concernant les services sociaux et aussi les services d'intérêt général non économique. Cette directive est venue encadrer les procédures internes aux EM et vient encadrer les autorisations administratives préalables

En matière économique, une autorisation est une barrière à l'accès au marché → le DUE va commander la suppression de certains régimes pas nécessaire

La directive donne 3 séries de cadres :

- Elle encadre le fait d'instituer un régime d'autorisation préalable → pour ce faire, l'EM devra démontrer les 3 conditions posées par la directive : il faut que ce régime soit motivé par une raison impérieuse d'intérêt général, qu'elle soit proportionnée (cad qu'une mesure contraignante n'aurait pas suffi) et enfin qu'elle ne doit pas être discriminatoire.
- La directive vient également encadrer les conditions d'octroi des autorisations. Les critères doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d'IG et proportionné à l'objectif visé ; mais en outre elle impose des critères d'octroi transparent, et puis surtout, elle n'encadre a priori pas la durée de l'autorisation → sauf dans 1 cas : elle va limiter la durée d'autorisation si le nombre d'autorisation est lui-même limité.
- La directive va imposer dans certain cas une procédure de sélection des candidats, une mise en concurrence des demandeurs d'autorisation imposé quand le nombre d'autorisation est en nombre limité.

Exemple de conséquence de la LPS sur le droit national.

Cette LPS a eu des conséquences concrètes sur le plan national :

A remis en cause certain monopole public, notamment dans certains secteurs de réseau → La LPS a permis l'ouverture dans ce secteur

Les jeux de hasard en ligne qui relève en principe d'un monopole de la FDJ, mais la CJUE a considéré que ce monopole n'était pas justifié par des raisons impérieuse d'IG et elle va imposer la libéralisation du secteur de jeux en ligne.

Évolution de 2010 = le monopole des jeux de hasard aurait pu être justifié, selon la Cour, si les EM avaient une politique mesurée en matière de jeux en ligne → cad que le monopole servait à éviter les dérives. Mais la Cour va relever que la FDJ a une attitude commerciale agressive allant à l'encontre de protéger qui que ce soit. Puis, concernant l'activité : certains pourraient dire qu'en ouvrant la concurrence au secteur on a un nouveau marché. En revanche, ce qui est vrai c'est que les jeux de hasard n'est pas une activité économique comme les autres (une des plus grandes addictions).

Autre exemple : **remise en cause des autorisations préalables** notamment dans le secteur des ventes volontaires de meuble aux enchères publiques.

= Ces ventes aux enchères étaient le monopole des commissaires priseurs qui devaient obtenir une autorisation administrative particulière mais le droit de la LPS est passée par là et à imposer en 2001 la remise en cause de ce monopole. Plus encore depuis 2010, il n'y a plus d'autorisation préalable de l'activité de ventes aux enchères.

Le DUE a imposé la mise en concurrence d'un type particulier d'autorisations administratives, dans l'hypothèse où ces autorisations administratives seraient limitées.

La question s'est posée s'il fallait mettre en concurrence les titres d'occupation du domaine public. Pendant longtemps il n'y avait pas d'obligation en la matière. Mais dans une décision de 2014 de la CJUE, *Promo Impresa*. Dans cet arrêt, la CJUE dit que les titres d'occupation sont en titre limité et doivent donc faire l'objet d'une autorisation préalable. → Ordonnance de 2017 qui est venu imposer la mise en concurrence des titres d'occupation domaniale si 2 conditions sont réunies :

- Si le domaine est le siège d'une activité économique
- Les autorisations sont en nombre limité

Partie 2 : Les activités économiques des PPB

Le régime des activités économiques lorsque celles-ci ont pu légalement créer une activité économique. On va parler du secteur public qui comprend l'ensemble des entreprises publiques pouvant prendre 2 formes :

- Les EPIC
- SA du secteur public (Les sociétés commerciales dans lesquelles une PPB possède la majorité du capital social)

Chapitre 1. Le régime du secteur public

Le secteur public est très récent en droit français, avant 1918 il n'existait pas d'entreprise publique, il n'existait pas les EPIC. Il existait des offices industriels et commerciaux.

Le secteur public va émerger après la seconde guerre mondiale → elle a conduit à une extension de ce secteur public avec de nombreuses nationalisations dès 1945.

Ce secteur public a commencé à croître de manière exponentielle → un secteur public national mais aussi local.

L'après 2^{ème} guerre mondiale est l'âge d'or du secteur public → le secteur public français avec des fonctions sociales, en plus des fonctions économiques. → Ces fonctions sociales ont fait que les

Reste que ce secteur public n'a de cesse d'être remis en cause depuis 40 → on peut parler d'un déclin du secteur public, surtout des politiques de privatisations mises en œuvre, qui vont faire sortir du secteur public de très nombreux types d'entreprise, sont sortis du secteur public toutes les banques nationales, tous les assureurs publics, mais aussi certains opérateurs économiques.

On peut craindre que l'État ne soit plus possesseur de la majorité du capital social de nombreuses entreprises.

L'État actionnaire ne prend plus des participations majoritaires, mais il se présente plutôt comme le soutien financier d'opérateur privé dès lors que l'État actionnaire a plutôt tendance à prendre des participations minoritaires.

Définition de l'entreprise publique : c'est le critère de la détention majoritaire du capital social → **CE, 1978, arrêt Schwartz**. → La majorité des droits de vote n'est pas déterminant pour qualifier l'entreprise publique, seul le critère capitalistique compte.

Il existe aussi une définition communautaire de l'entreprise publique. En DUE, l'entreprise publique se définit par 2 éléments :

- L'exercice d'une activité économique.
- Mais surtout, en DUE l'entreprise publique est celle sur laquelle la PPB va exercer une influence dominante (ce n'est pas forcément la majorité du capital social, cela peut être la majorité des droits de vote).
Cette notion ne s'applique que dans un cadre particulier : elle permet d'identifier les entreprises publiques soumises à une séparation de leurs activités monopolistiques et concurrentielles qui s'imposent qu'aux entreprises publiques (au sens de la directive de séparation).

Section 1. Le régime des opérations en capital des entreprises publiques

Ce régime a été principalement posé par le juge, puis codifié en 2014 qui a été édité par le gouvernement qui pose aujourd'hui toutes les règles d'entrée et de sortie du secteur public.

Paragraphe 1 : Le régime des nationalisations

C'est une opération par laquelle l'État va autoritairement retirer la propriété de l'entreprise à un opérateur privé, pour la faire rentrer dans le secteur public. Car en effet, la nationalisation autoritaire s'oppose à une nationalisation conventionnelle.

Il y a eu trois vagues de nationalisation dans l'histoire française → sous le Front populaire (1936), c'est aussi à cette époque que l'on a unifié des activités économiques qui étaient éparpillées parmi différents opérateurs, comme la SNCF.

→ Deuxième vague de nationalisation c'est l'après seconde guerre mondiale : on va nationaliser les entreprises qui servent à la reconstruction du pays. C'est les banques de dépôt, les assureurs, les compagnies énergétiques, le transport aérien ainsi que l'aéronautique.

Enfin, 1982 → avec la nationalisation d'autres banques, des industries importantes.

Régime juridique de ces nationalisations → on va se demander quelle est l'autorité compétente pour décider une nationalisation ? et quelles sont les règles substantielles à respecter ?

A. L'autorité compétente

Article 34 de la Constitution : la nationalisation relève de la compétence exclusive du législateur.

Tout du moins, la nationalisation autoritaire, celle qui est imposée par le législateur. Si la nationalisation est conventionnelle, celle-ci peut être de la compétence du gouvernement et non plus de la loi → Ordonnance du 20 août 2014. Cette ordonnance distingue selon qu'elle transfère la majorité du capital social : s'il y a transfert de la majorité du capital social il faut nécessairement un décret du PM alors qu'à l'inverse s'il y a transfert de propriété d'une part inférieure à la majorité du capital social, ces cas-là ne sont pas des nationalisations au sens juridique du terme et un simple arrêté du ministre suffira pour nationaliser.

B. Règles substantielles

L'autorité compétente va devoir respecter 3 séries de conditions :

- Elle va devoir respecter l'article 17 de la DDHC
- Elle doit respecter l'alinéa 9 du préambule de 46 qui semble poser une obligation de nationaliser dans certains cas
- Depuis quelques années, elle doit également respecter le droit des aides d'État, elle ne doit pas donner d'avantages économiques indus à l'opérateur économique

1. Le respect de l'article 17 de la DDHC

La propriété est un droit inviolable et sacré, et nul ne peut en être privé → sauf en cas de nécessité publique et à condition d'une indemnisation juste et préalable.

Le CE avait décidé d'appliquer dès 1982 cette disposition :

- Le juge va contrôler à la fois la nécessité de la nationalisation : elle ne contrôle quasiment pas cette nécessité. Il se réfère simplement à la motivation du législateur. En 1982, le législateur souhaitait lutter contre la crise

économique et le chômage. Ces éléments sont repris par le CC, le CC se contente de renvoyer à cette nécessité → il n'effectue aucun contrôle

- Ainsi que le caractère juste et préalable de l'indemnité → il a néanmoins effectué un contrôle sur ce point, ce qui l'a conduit à censurer la loi de nationalisation de 1982.

2. Le respect de l'alinéa 9 du Préambule de 46

Dès lors qu'on est en face à un SP public d'un monopole de fait, cette entreprise doit devenir la propriété de la collectivité → on a l'impression d'y lire une obligation de nationaliser les services publics nationaux ou les monopoles de fait.

Mais les juridictions nationales ont neutralisé la portée de ce Préambule → il n'y a pas d'obligation de nationaliser qui en résulte aujourd'hui.

Cette absence d'obligation de nationaliser, on l'a fait découler de la décision de la décision de 1982 du CC, le CC ne contrôle pas la qualification d'un SP national ou d'un monopole de fait.

Les juridictions nationales ont neutralisé la portée de cet alinéa à tel point qu'il n'y a plus d'obligation de nationaliser.

On la fait découler de la décision du **CC de 1982** : le CC ne contrôle pas la qualification d'un SP national ou monopole de fait. Le CC a voulu laisser une marge de manœuvre au législateur. Mais plus encore, il est certain aujourd'hui qu'on peut aller en deçà du préambule de 1946, il est possible de ne pas nationaliser un SP national ou un monopole de fait pour un gvt. Car en effet, ce texte ne prévoit aucune sanction et notamment aucune sanction contentieuse. La nationalisation s'opère par une loi donc le gvt devrait faire un projet de loi de nationalisation. Donc on devrait contester devant le juge administratif le refus de déposer un projet de loi de nationalisation. Mais le projet de loi est un acte de gouvernement insusceptible de recours. Ainsi il n'est pas possible de contraindre un gvt à nationaliser, cela relève d'un choix de politique publique.

3. Le droit des aides d'État

Il peut s'appliquer en matière de nationalisation dans la situation où l'état français nationalise une entreprise privée et qu'il verse un prix d'achat supérieure à la valeur de l'entreprise. L'état français opère un avantage économique à l'opérateur donc la nationalisation peut tomber sous le coup d'aide d'état.

Exemple : en 2017 à propos de la SNCM : entreprise en difficulté et l'état a voulu vendre pour 1 euro symbolique mais cela est bien inférieure à la valeur de l'entreprise en question.

I) Les cessions de participation

Cela peut être une cession de participation minoritaire. Dans une telle hypothèse ce n'est pas une privatisation. La privatisation impliquant le transfert au secteur privé d'activité.

Il ne peut y avoir privatisation qu'en cas de cession de la majorité des associés.

La privatisation ce n'est pas une externaliser l'activité, ni délégué l'activité en effet elle implique un transfert d'activité au secteur privé.

La privatisation ce n'est pas la soumission à un régime de droit privé, en réalité si mais ce n'est pas une sociétisation. Ce n'est pas transformer une personne publique en SA.

On peut sociétiser une personne publique (la Poste qui était un EPIC est devenu une SA).

Ces privatisations ont commencé en 1986 sous le gouvernement Chirac et ont poursuivi en 1993 sous le gvt Balladur. Puis ensuite en 1997 avec le gvt Jospin. Elles ne se sont pas arrêtées au XXIème siècle. On a privatisé l'exploitation des autoroutes en 2025, des aéroports locaux. Puis on a privatisé en 2019 la française des jeux ainsi que l'aéroport de Paris.

A) Les participations susceptibles d'être cédées

Alinéa 9 préambule de 1946 : pas possible de privatiser les monopoles de fait si les SP nationaux si on s'en tient à sa lecture.

1) L'interdiction de privatiser les monopoles de fait

Les monopoles de fait ont été identifiées par le CC : **CC, 25 et 26 juin 1986, loi de privatisation**

= le juge va contrôler une loi de privatisation. Il a identifié le monopole de fait et l'a défini. Identification selon deux critères cumulatifs :

-L'opérateur détient une position exclusive ou prépondérante dans un secteur important de l'économie nationale.

-Ce secteur d'activité représente sa majeure partie de son activité globale.

Le CC tente bien d'identifier un monopole de fait sur un marché et le CC n'identifie pas de marché pertinent au sens du droit de la concurrence. Il opère une analyse peu rigoureuse.

Le CC en pratique n'a jamais reconnu de monopole de fait dans sa jp dans le but de permettre la privatisation systématiquement.

Exemple : en 1986 lors de la première vague de privatisation, le requérant ne considérait pas possible de privatiser la société Thomson qui appartenait à l'État car seul producteur pour les armées et n'aurait pas pu être privatisé en 1986. Le CC va balayer cette argumentation et va tordre l'analyse économique pour considérer qu'il n'y avait pas de monopole de fait.

En 2006 à propos de Gaz de France : le CC a considéré que Gaz de France n'était pas en situation de monopole de fait (alors qu'aucune concurrence sur le marché).

Le CC a aussi dénié le monopole de fait à la française des jeux et aéroport de Paris.

Le CC agit de cette manière car il souhaite adopter la neutralité la plus forte possible en matière de politique économique : il ne s'oppose pas aux nationalisations ni aux privatisations.

2) Interdiction de privatiser les SP nationaux

SP national : le CC n'a jamais défini les SP nationaux. Et le CC distingue les SP nationaux constitutionnels = pas possible de privatiser.

#

Des autres SP nationaux pour laquelle la privatisation est plus facile même si tjrs compliquée.

SP nationaux constitutionnels : le CC se réfère fréquemment à cette catégorie. La difficulté c'est que les limites de cette catégorie demeurent incertaines. En d'autres termes, le CC n'a jamais défini positivement ce qu'est un SP national constitutionnel, on n'a aucun exemple. Le CC s'est contenté de dire que certains SP ne sont pas des SP nationaux constitutionnels comme par exemple l'activité bancaire, l'électricité et le gaz, le SP des autoroutes.

On ne peut pas les privatiser mais on ne sait pas ce que c'est.

En doctrine on dit que sont constitutionnels les SP régaliens (la défense, la police, la justice, la diplomatie, l'éducation). Ce sont ces SP qui font une interdiction de privation absolue.

Les autres SP nationaux (législatifs) : le fait que le SP soit qualifié de national par la loi n'empêche pas sa privatisation. Il est possible de privatiser le SP national (CC, 25 et 26 juin 1986). Le CC va quand même vérifier si le SP a les caractères d'un SP national au sens de sa jp.

Définition en droit positif qui est celle du CC et du CE :

= CC, 2006 relative à la loi énergie et CE, 2006 avis relative à GDF :

2 éléments :

- Un SP confié par la loi à une seule entreprise.
- Un SP dont l'organisation a été fixée au niveau national.

Cette définition est peu utile en pratique. Le SP national est confié par le législateur à une seule entreprise en d'autres termes c'est un monopole de droit. Dans ce sens, le CE a pu considérer que la mission confiée à GDF a été qualifiée de SP national en 2004 mais en deux ans plus tard il a considéré que ce n'était plus un SP national en raison de la libéralisation prochaine du marché.

Il faut que cette entreprise soit la seule au niveau national donc un monopole national, à l'échelon nationale. Le CE devait se prononcer en 2005 sur la qualité de SP nationale des autoroutes publiques = il a considéré que cela en été pas même après la privatisation et même lorsqu'il existait plusieurs opérateurs chargés de cette activité sur le territoire.

= donc il admet leur privatisation.

En 2019, la partie de la population n'était pas favorable à la privatisation de l'aéroport de Paris et c'est à cette occasion qu'a été mise en place la première procédure de

RIP. Le RIP nécessite un certain nombre de signatures d'électeurs pour que la procédure se poursuive et ici pas assez donc le RIP n'a pas abouti.

B) Les autorités compétentes en matière de privatisation

Ces autorités compétentes :

-Le législateur : compétence qui résulte de l'article 34 de la C°. Ceci étant cette compétence législative n'est pas absolue et il existe des hypothèses dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut décider d'une privatisation.

1) Compétence de principe du législateur

En pratique la décision de privatiser est prise par décret mais ce décret ne peut intervenir que sur autorisation du législateur donc il faut une loi en ppe pour privatiser. Ceci étant l'ordonnance de 2014 délimite cette compétence législative et en réalité le législateur est compétent que dans les cas suivants :

-Le législateur est compétent quand l'état détient plus de 50% du capital social depuis plus de 5 ans. L'état doit détenir directement cette participation. Si détenu à la fois par l'état et par d'autres personnes publiques = pas de détention direct du capital social par l'état. Il ne peut pas y avoir de détention conjointe du capital social.

CE, 2006, Bayrou : Il ne faut pas que la répartition entre plusieurs personnes du capital soit fictive. Dans une telle hypothèse ce n'est pas une détention directe et donc plus besoin de loi. L'état pourrait répartir la détention du capital social pour faciliter la privatisation. Il faut vérifier si les personnes publiques ne détiennent pas des parts fictives dans le seul but d'éviter que l'état soit majoritaire. Le juge vérifie si l'actionnaire publique dispose de mission nationale, de moyen spécifique pour mener à bien cette mission.

-Le législateur est compétent soit si l'entreprise a un effectif de plus de 500 salariés ainsi que de ses filiales ou chiffres d'affaires qui dépasse 75 millions d'euros (critères alternatifs).

Seules les plus grosses privatisations d'une grosse entreprise publique font intervenir le législateur.

L'intervention du législateur sera nécessaire si l'entreprise a été nationalisée par la loi. Il faudra nécessairement un acte législatif pour la privatiser et ce en dérogation des critères mentionnés.

2) Le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire sera compétent dans tous les autres cas cad les hypothèses où les seuils cités ne sont pas atteints. Le pouvoir réglementaire compétent sera en ppe le PM (décret en conseil des ministres).

En matière de privatisation il faut fixer un prix qui soit en rapport avec l'opération. Le prix de la privatisation peut parfois être qualifié d'aide d'état au sens du DUE. Les aides d'état sont prohibées par le DUE. Une opération de privatisation peut être

qualifié d'aide d'état par exemple si l'état vend une entreprise publique à un prix inférieur à sa valeur et bien une telle vente est interdite en ppe et aussi un avantage pour l'opérateur qui en bénéficie. Autant il y a des entreprises publiques facile à céder autant il y en a qui n'ont pas forcément d'acheteur Par conséquent, il peut être tentant pour la personne publique de minorer le prix.

Section 2 : La gouvernance des entreprises du secteur public

Gouvernance organisée par le titre 2 de l'ordonnance de 2014.
Ces dispositions prévoient des dérogations au droit des sociétés car en principe, c'est le droit commun des sociétés qui s'applique aux entreprises du secteur public.

I) Les organes des SA du secteur public

C'est le droit commun des sociétés qui s'applique : conseil d'administration, conseil de surveillance, pourront y siéger l'état actionnaire qui n'aura qu'un représentant. On va trouver des représentants des salariés dans les entreprises publiques depuis 1983. On a voulu associer les salariés à la gestion de l'entreprise publique.

Particularité de la composition du Conseil : l'état peut parfois proposer des membres à ces conseils. Il peut proposer tel membre même s'il est minoritaire dans l'entreprise. Cela est admis dans la loi dès la détention de 10% du capital social.

Le régime juridique des membres : droit commun des sociétés.

Dans les entreprises publiques c'est la présence du commissaire du gouvernement : c'est celui qui représente les intérêts de l'État et ce commissaire peut être désigné par l'État dès lors que l'État a un représentant au sein du Conseil. Il n'a qu'un pouvoir que limité (ses organes n'ont qu'une voix consultative et n'est là que pour exposer la politique du gvt dans le secteur d'activité concerné).

Les dirigeants de ces entreprises publiques où l'État est majoritaire : c'est la puissance publique qui désigne ces dirigeants. Ils sont nommés par décret du PM signé en conseil des ministres donc le PR a aussi son mot à dire.

II) L'action spécifique

C'est une action qui ne peut appartenir à l'État au sein d'une entreprise publique et va conférer à l'état des prérogatives particulières relevant du contrôle de l'état sur l'entreprise. Cela opère une rupture totale d'égalité entre actionnaire dès lors que l'état actionnaire dispose d'action spécifique.

Michel Bazex : la privatisation serait le stade suprême de l'interventionnisme ?

Elles ont été mises en place dès 1986 et sont encadrés par l'ordonnance de 2014.

A) Les conditions de l'action spécifique

L'action spécifique ne peut pas être instauré dans n'importe quelle entreprise.

-A l'occasion d'une procédure de privatisation.

-Elle doit viser à protéger les intérêts essentiels du pays (= on peut intérêt une action spécifique pour les entreprises stratégiques de l'état notamment en matière de défense). Ce sont les intérêts essentiels du pays en matière d'OP et de santé et de sécurité publique.

-Elle est instaurée par décret édictée avant l'évaluation de la société privatisée. L'action spécifique a un impact sur la valeur de la société.

Les effets de l'action spécifique :

-L'action spécifique permet de subordonner à agrément certaine prise de participation dans l'entreprise précisément il peut être prévu que le ministre de l'économie puisse donner son agrément lorsque des participations franchissent un seuil déterminé. Ce type d'action spécifique permet à l'État de s'opposer à certaines prises de participation notamment étrangère.

-Le gvt pourra nommer plus de représentants au sein du CA et Conseil de surveillance. Cette possibilité est moins fréquente que la première.

-L'action spécifique pourra aussi permettre aux ministres de s'opposer à certaines cessions d'actif notamment qui compromettrait les intérêts nationaux.

Les effets contractuels qui permettent de contrôler la composition du capital social : contrôler toute prise de participation : l'état français vient contrôler les prises de participation dans des entreprises qui ne sont pas publiques et donc une réglementation de prise de participation étrangère qui existe aujourd'hui.

B) La compatibilité de l'action spécifique avec le DUE

Une action spécifique à elle aussi pour effet de limiter la circulation de capitaux. Ceci étant, il est possible de porter atteinte aux libertés de circulation notamment pour des raisons impérieuses d'IG.

En 1997 la Commission européenne va considérer que l'action spécifique porte atteinte à la libre circulation des capitaux mais cette atteinte peut être justifiée dans certains cas. NE 1997, la Commission ne va pas se contenter de la justification de raison impérieuse d'IG mais de 4 justifications :

- L'action spécifique doit être justifiée par des raisons impérieuses d'IG
- Elle ne soit pas être discriminatoire
- Elle doit être adéquate
- Elle doit être proportionnée aux objectifs poursuivis

La CJUE l'a repris à son compte et l'a appliqué en 2002

= **CJCE, 2002, Commission c. France** : action spécifique instituée dans société Elfe Aquitaine qui prévoyait une autorisation du ministre de franchissement d certains

seuils de prise de participation. La CJUE devait se prononcer si elle remplissait les 4 éléments de justification posés en 1997. La CJUE va considérer que l'action spécifique 'est pas compatible avec le DUE concernant Elfe Aquitaine car la mesure est disproportionnée. Le régime d'autorisation du ministre ne posait pas problème mais c'était le pouvoir discrétionnaire du ministre dans ce régime d'autorisation car ce n'était pas marqué selon quel critère le ministre pouvait refuser le franchissement de seuil.

Quelles sont les raisons impérieuses d'IG permettant de justifier une action spécifique ?

= la CJUE a considéré que la garantie d'un service d'IG constitue une raison impérieuse d'IG. Mais à l'inverse, la CJUE a considéré que l'action spécifique portugaise : le gvt portugais considérait que l'action spécifique permettait le maintien des services de télécommunication en temps de guerre. Mais ici la CJUE ne voit pas une raison impérieuse d'IG.

Santé publique = raison impérieuse d'IG.

Action spécifique = Golden chair

Chapitre 2 : Les formes juridiques des entreprises publiques

L'entreprise publique c'est soit une SA du secteur public soit un EPIC.

Section 1 : EPIC

L'EPIC est un établissement public chargé d'un SPIC.
Il est soumis à un statut très hybride qui fait appel autant au droit public que privé.

I) Le régime de l'EPIC

Ce régime fait une large place au droit privé. Un EPIC n'est pas soumis en ppe de comptabilité publique. Il a des relations de droit privé avec ses agents et usagers. Il est facile de considérer d'emblée que le régime de l'EPIC est un régime de droit privé mais cela serait hâtive.

Les EPIC sont créés en ppe par la loi. Une loi spéciale va créer chaque catégorie d'EPIC qui peut être différente d'un EPIC à un autre. Ces statuts des EPIC sont variables. On constate un régime mixte des EPIC dans lequel on va parfois appliquer le Droit public et y déroger ou droit privé et y déroger aussi.

A) Principe de spécialité des EPIC

C'est un ppe général du droit administratif depuis 1938. Il est contraignant pour les EPIC, suivant ce ppe, l'EPIC ne peut intervenir que dans les domaines du texte qui l'a institué. L'EPIC doit exercer des activités en lien direct avec les dispositions statutaires de l'EPIC.

Ce ppe de spécialité a été appliqué de manière rigoureuse par le juge administratif mais il est appliqué de manière plus souple par le CE depuis quelques années.

Ce ppe de spécialité a un inconvénient car cela empêche à l'EPIC de se diversifier. C'est pour cette raison que les juridictions nationales ont assouplis le ppe de spécialité des EPIC.

CE, 1994, avis relatif à la diversification d'EDF GDF : dans cette décision, le juge va rappeler le ppe de spécialité mais tout en opérant ce rappel le CE va dire qu'il est possible pour un EPIC de se diversifier, se livrer à d'autres activités économiques à deux conditions :

-Il faut que la nouvelle activité soit le complément normal de l'activité principale (lien de connexité avec l'activité principale).

-Il faut que l'activité nouvelle soit une activité d'IG et utile à l'entreprise.

Le CE a permis en 1994 que EDF fasse des activités de traitement de déchets, de distribution d'énergie = toutes ses activités sont le complément normal de son activité principale. En revanche, les activités de télé-surveillance n'ont aucun lien avec son activité principale et ne peuvent être exercées.

Il y a eu un contentieux qui a duré presque 20 ans :

Hôpitaux publics qui ont des activités variées dépassant leur activité de SP : à l'hôpital public on lave du linge. On s'est demandé si un hôpital public pouvait se diversifier et vendre des services de blanchisserie.

Le CE a considéré il y a 20 ans que cela n'avait aucun lien avec l'hôpital. Les juges du fond ont changé d'avis : CA Marseille, 2018 a considéré que l'activité annexe de blanchissement constitue une activité complémentaire à son activité principale.

B) Absence de soumission des EPIC aux voies d'exécution de droit privé

Les biens des personnes publiques sont insaisissables : PGD en 1987

Ce PGD est aujourd'hui inscrit dans la loi : article L2311-1 CGPPP

Les voies d'exécution de droit privé ne sont pas applicables aux personnes publiques. Non seulement elles ne sont pas applicables mais ne sont pas applicables non plus les procédures collectives = article L620-2 Code de commerce.

Ici on a un régime dérogatoire au droit privé justifié par le caractère public de l'EPIC.

C) La prohibition du recours à l'arbitrage

Pour un opérateur économique, l'arbitrage permet d'éviter la saisine d'un juge (coûteux, long). Le monde du commerce préfère la justice privée. L'arbitrage permet un règlement rapide et efficace entre commerçants.

Le régime des EPIC n'est pas favorable à l'arbitrage. En effet, par ppe une personne publique ne peut pas avoir recours à l'arbitrage : PGD depuis CE, 1986, avis Euro Disneyland

Cette solution est aujourd'hui codifiée dans le code civil : **article 2060 code civil**.

La solution s'explique par le régime de l'arbitrage : un arbitre n'a pas l'obligation de statuer en droit, il peut se prononcer en équité donc au-delà des règles de droit. Pouvant être contraire à la légalité (pas négociable pour une personne publique). Une décision arbitrale pourrait porter atteinte à la continuité du SP et c'est pour préserver cela que l'on prohibe l'arbitrage aux personnes publiques. Mais cela ce n'est que le ppe.

Ce ppe fait l'objet de nombreuses dérogations :

-Il est admis qu'une loi ou convention internationale puisse autoriser une personne publique à recourir à l'arbitrage (= loi du 19 août 1986 qui a permis l'arbitrage dans le lien entre l'état français et euro Disneyland).

Les EPCIC sont souvent créés par une loi spéciale et parfois la loi spéciale prévoit cette possibilité de recours à l'arbitrage.

-Dérogations prévus par le code civil : **article 2060 alinéa 2 code civil** : un décret va pouvoir autoriser des catégories d'EPCIC à compromettre. Le CE a rapidement limité cette portée. Pour le CE l'autorisation de compromettre ne peut être accordée qu'après la naissance du litige. En d'autres termes, cette disposition ne permet d'insérer des clauses compromissaires. Elle est insérée avant le litige. L'article permet seulement de compromettre après la naissance du litige.

-Dans les principaux contrats de la commande publique : marché de partenariat, marché de travaux de fourniture qui peuvent faire l'objet d'un arbitrage : inscrit dans le code la commande publique.

Cette prohibition à l'arbitrage a voulu être remise en cause. C'est un handicap commercial pour les EPIC. En 2007, un groupe de travail a voulu renverser la prohibition de ppe cad d'admettre l'arbitrage par ppe et cela n'aurait été que par dérogation que l'arbitrage aurait été interdit. CE rapport a été très bien accueilli. Ce rapport n'a été d'aucun effet après 2007 donc aucun texte aujourd'hui n'a renversé le ppe.

Rapport en 2025 par Thomas Clay spécialiste de l'arbitrage : prévoit de reprendre la solution de 2007. Il y a des chances que ce rapport soit suivi.

L'arbitrage quand il est autorisé par dérogation il doit être contrôlé par le CE. Il existe un contentieux d'arbitrage des personnes publiques.

D) Les dérogations au droit de la doménialité publique

Dans les années 90, on trouve des textes législatifs qui ont sorti du domaine public des biens de certains EPIC ou soumis à un régime sui generis. Exemple : certains biens d'EDF (biens pas nécessaires à la continuité du SP). C'était des biens qui avaient un intérêt économique pour l'opérateur. Cela permet la valorisation de ces biens des EPIC.

Quel est l'intérêt de faire sortir un bien d'un EPIC du domaine public pour le soumettre au droit privé ?

Si on sort un bien du domaine public, il pourra être donné en garantie. S'il est dans le domaine public il est insaisissable et on ne peut rien en faire.

II) La crise de l'EPIC

Le statut d'EPIC tend à décliner et on constate depuis une vingtaine d'année c'est un phénomène de transformation des EPIC notamment en SA. Ce phénomène c'est la sociétisation des EPIC. Il est certain que certains EPIC notamment les EPIC nationaux sont condamnés par le DUE : considéré comme aide d'état par l'UE.

A) La sociétisation des EPIC

En 1996, le CE considérait que l'EPIC était une modalité datée de l'organisation du SP.

L'EPIC serait condamné.

On constate un mouvement de transformation de la plupart des EPIC nationaux en SA.

Exemple : L'aéroport de Paris transformé en SA en 2005, la poste transformée en SA en 2010, EDF et GDF dès 2004, France Télécom en 1996.

Pour quelle raison cette évolution a eu lieu ?

-L'intérêt premier c'est de pouvoir mener une politique de diversification et donc ne pas être contraint par le principe de spécialité qui s'applique aux EPIC.

-Lorsqu'on est une SA : appel public à l'épargne (financement sur les marchés financiers). Ça a été le cas avec France télécom : on transforme en SA et on privatise et la privatisation a été contractuelle et a permis à une grande partie un appel public à épargne.

-Le droit de la commande publique : c'est un droit très contraignant qui s'applique aux EPIC pour la satisfaction de leur besoin. Dès lors que l'EPIC devient une SA, il n'est plus soumis à la commande publique et peut conclure librement des contrats avec ses fournisseurs.

Il existe que quelques EPIC au niveau national aujourd'hui.

B) La comptabilité des EPIC avec le droit des aides

La Commission européenne dès 2000 a relevé ce problème : le statut d'EPIC pose problème car ce statut confère des avantages trop importants aux commerçants publics. Ces avantages sont ceux qui sont tirés des régimes des EPIC.

Les biens des EPIC sont insaisissables, ils ne sont pas soumis aux procédures collectives et ces avantages résultent de la garantie illimitée de l'État. Si un EPIC gère mal son activité et bien l'État sera tjrs là pour renflouer ces caisses.

Ce qui a posé problème sont les conséquences de ces garanties illimitées de l'État : emprunteur potentiel qui n'aura jamais de difficulté à rembourser ses dettes. L'EPIC pourra emprunter à des taux quasi nuls.

Face à cette position de la commission qui a été donné dès l'année 2000, l'état français n'a rien fait et le CE a consacré une étude aux EPIC en 2009 dans laquelle le CE va dire qu'il n'y a aucun problème au regard des statuts d'EPIC et va dire que cette garantie ne pose pas de problème et pour éviter que cette garantie soit un avantage, il faudrait que l'état soit rémunéré pour cette garantie.

Comment rémunérer une garantie illimitée ?

= cela n'existe pas sur les marchés. Cette contrepartie proposée est improbable. La solution proposée par le CE paraissait douteuse en 2009.

CJUE, 3 mai 2014, Commission c. France : sur le statut d'EPIC de la poste
= le juge considère qu'il existe une présomption de garantie illimitée de la part de l'État et de cette présomption le juge en déduit une présomption d'avantage : la possibilité de se financer mieux sur les marchés bancaires.

Cet arrêt a été commenté comme ne condamnant pas le statut de l'EPIC. Certains auteurs disent que le CJUE pose une présomption d'avantage mais présomption simple. Donc se pose la question de renversement de cette présomption.

Concernant ce deuxième point, la CJUE s'est à nouveau prononcé en 2018 : **CJUE, 2018, Commission c. France** : affaire IFPEN

= La CJUE confirme le raisonnement de 2014 et la CJUE va admettre qu'il est possible de renverser cette présomption mais dans des conditions excessives que le renversement semble impossible en pratique.

La Cour considère qu'il faut démontrer que l'EPIC n'a pas bénéficié de cette garantie illimitée mais elle va plus loin car elle exige la démonstration que l'EPIC n'obtiendra pas d'avantage dans l'avenir. Il est possible de prouver cela à un moment mais pas possible de prévoir cela dans l'avenir. En théorie cela est possible mais impossible dans la pratique. L'EPIC semble condamné par cette jp.

Certains auteurs proposent une dernière solution pour sauver les EPIC français : pour les services d'IG il existe une dérogation donc on pourrait déroger au droit des aides pour l'EPIC dans l'IG = **article 106 §2 TFUE**

= admet les dérogations au droit du marché mais une dérogation proportionnée. On pourrait considérer qu'une garantie illimitée est accordée dans l'IG. La garantie dès lors qu'elle est illimitée est disproportionnée.

C'est pour cette raison que l'on ne crée plus d'EPIC. Il y a encore bcp d'EPIC locaux mais plus d'EPIC nationaux car pas compatible avec le droit des aides.

On est en face d'une solution qui limite le mode de gestion du SP.

Section 2. Les SA locales à statut spécifique

Elles sont contrôlées par des PPB.

Est-ce qu'une personne publique peut être actionnaire d'une SA → une PPB actionnaire, la question est positive concernant l'État, l'État français est actionnaire de différentes SA.

Mais si l'État peut prendre des participations ; la question est plus délicate concernant les collectivités territoriales et les EPIC.

Est-ce qu'un EPIC peut lui-même être actionnaire de SA ; peut-il servir de holding ?

La réponse à cette question ne résulte d'aucun texte, elle est positive du fait de la pratique → on a vu en pratique la constitution d'un EPIC comme holding avec SNCF.

En pratique, elle ne se pose quasiment jamais → la réponse à cette question est très différente concernant les collectivités territoriales, à l'inverse de l'État les collectivités n'ont pas le droit d'être une société anonyme. Par conséquent, le principe est tjr existant, c'est l'interdiction pour une PPB locale de prendre une participation → mais cette interdiction a largement reculé en droit positif → cette position date de 2015 et la loi NOTRE qui va autoriser les régions à prendre de telles participations. →

L'article L4211-1 CGST

LA prise en participation d'une région peut s'analyser en une aide d'État et est très encadrée par le droit des aides.

Les communes et départements → le principe c'est l'interdiction de prise en participation des SA sauf dérogation prévues par certains textes, elles sont limitées. Depuis 2015, les communes peuvent prendre des participations dans des sociétés commerciale d'énergie renouvelable et ici il y a un texte spécial qui autorise cette participation → **L2253-1 CGCT**

Mais les collectivités locales peuvent prendre des participations dans les sociétés locales à statut spécifique qui peuvent prendre aujourd'hui 3 formes. Ces 3 formes sont des sociétés anonymes de droit commun, des SA qui sont soumises au droit des sociétés sauf disposition spéciale → ces 3 formes elles vont révéler des financements différents :

- 1^{ère} forme : la **SEM (société d'économie mixte) locale**, c'est une société dans laquelle la PPB est majoritaire en capital social, mais celui-ci va nécessairement comprendre des opérateurs privés.
- 2^{ème} forme : en 2010 ont été créés les **SPL qui sont les sociétés publiques locales** : société anonyme dont le capital est entièrement détenu par des PPB
- 3^{ème} forme : c'est la **SEMOP** créée en 2014, c'est une société d'économie mixte avec un seul actionnaire privé qui a été choisi après une procédure de mise en concurrence.

Les intérêts de recours à ces structures :

- De pouvoir obtenir des financements privés à certains projets d'intérêt général. Cette mission va être financée partiellement par l'actionnaire privé.
- Tient à ce que la SA peut se diversifier plus facilement qu'un établissement public → les CT ont donc plus intérêt parfois à créer une SA à statut spécifique
- L'avantage certain tient à l'application du droit privé à ces sociétés

Paragraphe 1 : Les SEM locales

L1521-1 et suivants du CGCT → ils définissent quels peuvent être l'objet social d'une SEM. Elle peut avoir 3 objets différents :

- Exploitation d'un service public industrielle et commerciale.
- Elle peut aussi réaliser des opérations d'aménagement.
- Elle peut réaliser toute autre opération d'IG → on peut charger une SEM d'une mission de SP quelle qu'elle soit. Sur ce point, le juge a pu dire que la SEM n'a pas besoin de démontrer une carence du marché pour créer une activité économique → **CE, 2010, décision syndicat national des agences de voyage**

Ceci étant dit, la première question qui doit nous intéresser c'est l'organisation du fonctionnement de la SEM locale

A. L'organisation du fonctionnement

En principe, c'est le droit commun des sociétés qui trouve à s'appliquer, sauf dérogation prévue par le CGCT

Plusieurs dérogations :

- Dans une SEM, la personne publique doit détenir entre 50 à 85% du capital social. Cela signifie que la PPB doit être majoritaire au sein de la SEM. La SEM implique nécessairement la présence d'actionnaires privés, il faut au moins 15% d'actionnaires privés
- Dans une SEM, la PPB a forcément un représentant en conseil de surveillance.
- La collectivité est considérée comme dirigeant de la SEM. Les représentants de la collectivité exercent des mandats au sein de la société c'est donc la collectivité qui est responsable des actes de la SEM et assume la responsabilité des dirigeants dans le cadre d'une procédure ...
- La CT va devoir apporter des garanties à la société, notamment des garanties d'emprunt. Lorsqu'une collectivité accorde une telle garantie, elle a le droit à un délégué spécial → Précisément à la garantie en question

La SEM qui a été créée par une CT va intervenir pour le compte de ses actionnaires, mais la loi autorise cette SEM à intervenir pour son propre compte ainsi qu'à intervenir pour le compte de tiers → la SEM n'a pas vocation à intervenir que pour la collectivité.

Aujourd'hui, toute SEM est contrôlée par sa collectivité actionnaire, elle doit rendre un rapport annuel à sa collectivité actionnaire. Mais plus encore il peut exister un contrôle d'État du préfet sur la SEM, sur certaines décisions prises par la SEM, certaines décisions prises par le Conseil d'A de la SEM.

Ensuite elles sont contrôlées par un commissaire aux comptes comme toute SA. Elles sont contrôlées par les CRC (chambre nationale des comptes) qui rendent des rapports d'observations sur les SEM au niveau local.

On voit bcp de SEM se créés en matière de production des énergies renouvelables
→ la difficulté c'est que l'on voit très souvent des sociétés créées dans des situations étranges. La Cour des comptes s'est prononcées sur la création d'une SEM.

B. La relation de la SEM avec la collectivité qu'il l'a créée

La SEM est un mode d'organisation qui est en déclin depuis 2005, en tout cas dans certains secteurs → surtout quand on veut confier à la SEM la gestion d'un SP.

La plupart du temps, une commune crée une EM pour gérer un SP local. Le problème c'est que pour confier un SP à un tiers il faut conclure un contrat de concession d'un SP. → Qui implique une procédure de mise en concurrence

Ceci étant, au début du XXIème siècle, on s'est demandé si les SEM ne pouvaient pas bénéficier d'une dérogation à la mise en concurrence. → Type de dérogation : exception in house où la PPB contrôle la personne tierce et la collectivité n'a donc pas à mettre en concurrence l'opérateur en question avec les autres opérateurs économique.

La CJCE a pris une position de principe en **2005 avec la décision Schdthalle** → décision dans laquelle la Cour va considérer que l'exception in house ne peut pas s'appliquer dans les relations entre la collectivité et la SEM, en raison de la présence d'actionnaire privé au sein de la SEM. → dès lors qu'il y a un A dans la SA, il ne peut pas avoir l'exception in house. Pour la CJCE, la PPB doit mettre en concurrence la SEM avec les autres opérateurs économiques si elle veut lui faire gérer le SP.

Depuis 2005, aucune SEM n'a été créée en France depuis cette décision-là.

C'est en raison de cette difficulté que le législateur est intervenu en 2010 → en 2010 ont été créés les SPL

Paragraphe 2 : Les SPL

C'est une SEM dont le capital est entièrement public → pourquoi cette création ? pour faire jouer l'exception in house

Dès lors que l'on peut créer une société avec que des actionnaires publics on peut faire jouer l'exception in house.

Cela paraissait très optimiste → la SPL a partiellement échoué du moins dans certaines situations et parfois l'exception in house ne s'appliquera pas dans les relations entre la SPL et la collectivité

Car il faut que la PPB ait un contrôle effectif sur l'opérateur in house → un contrôle étroit sur les orientations de l'Opérateur in house, sur ses décisions importantes. Il n'y a de contrôle étroit que si la PPB peut avoir une influence sur les décisions de la société in house.

La CJUE a constaté que ce contrôle effectif n'est pas systématique même en cas de SPL.

Exemple : On crée une SPL par deux communes et un département. La première commune dispose de 40% capital social la deuxième aussi et le département dispose de 10% du capital social. On peut avoir un 4^{ème} actionnaire qui a 0,5% de capital social. Dans une telle situation, les communes qui ont bcp de capital social peuvent contrôler les décisions de la société. Donc une part importante de capital social permet un contrôle effectif. À l'inverse, si la collectivité n'a pas bcp de capital social, elle n'exerce aucun contrôle sur les décisions de la société, elle n'est même pas représentée dans certains cas au conseil d'administration. L'actionnaire ultraminoritaire n'exerce pas de contrôle effectif sur la vie de la SPL donc l'exception in house ne pourra pas s'appliquer dans les relations entre l'actionnaire minoritaire et la SPL.

Si les deux premières communes le souhaitent affecter un SP à la SPL = exception in house donc pas besoin de mise en concurrence

En revache la 3^{ème} commune qui souhaite affecter un SP à la SPL = devra mettre en concurrence car pas d'exception in house.

Question de la **CJUE de 2012 dans une très importante affaire Oconord**, approche confirmée par le **CE, 2013, décision Commune de Marsannay-La-Côte** : il faut vraiment exercer un contrôle effectif sur la SPL pour faire jouer l'exception in house.

Paragraphe 3 : Les SEMOP

Article L1541-1 s. CGCT depuis une loi du 1^{er} juillet 2014

Ce texte législatif s'inspire d'une décision de la **CJUE de 2009 : affaire Acoset** = la CJUE a considéré que l'exception in house peut jouer dans les relations entre une SEM et les collectivités à la condition que l'actionnaire privé de la société soit lui-même choisi après une mise en concurrence.

Cette solution a été reprise par le législateur français en 2014.

-Ce sont des sociétés opération unique. En d'autres termes, la SEMOP ne peut agir que pour la réalisation de son objet social. Une SEMOP ne peut pas se diversifier.

-La SEMOP est conclue dans le but de conclure un contrat de SP en dehors de toute mise en concurrence. Donc sa durée va être particulièrement limitée à la durée du contrat qu'elle conclut avec la collectivité. A l'issue de ce contrat l'objet social de la SEMOP aura été réalisé et à l'issue de ce contrat, la SEMOP sera dissoute.

-Contrairement à la SEM, l'actionnaire public peut contenir entre 34 et 85 % de capital social dans une SEMOP. Donc dans une SEMOP la personne publique peut être minoritaire et même en étant minoritaire ça n'empêchera pas de contrôler la société en question.

En conclusion, ce sont des modes de gestion très courants du SP, ce sont des sociétés créées dans un but purement commercial. Ces sociétés sont très fréquentes. La SEM est l'illustration même du DPA.

PARTIE 3 : La puissance publique et les opérateurs économiques

Une 3^{ème} partie où on va envisager la PPB dans un rôle d'encadreur de l'économie
→ la PPB n'est pas qu'un acteur du marché mais aussi le régulateur du marché.

Chapitre 1 : La réglementation des prix

La police des prix c'est le pouvoir de fixer le prix des biens et des services sur le marché → la fixation va clairement à l'encontre d'une liberté de détermination de ces prix, à l'encontre de la liberté d'entreprendre.

La police des prix peut prendre des formes très variées. Cela peut être la fixation d'un prix par la puissance publique. Mais ce peut également être un contrôle par un système de déclaration ou d'autorisation préalable.

Cette police des prix peut être mise en œuvre par plusieurs types d'instruments juridiques → acte réglementaire, acte unilatéral, mais aussi dans par des clauses réglementaires d'un contrat administratif.

Ou directement par le biais de contrat → contrat dérégulation tarifaire → conclu en matière d'aéroportuaire

La police des prix remonte à l'ancien régime, elle n'a quasiment jamais été rompu depuis lors. On peut citer certaine période propice à la police des prix : la Révolution française, la crise économique des années 30, Vichy, à la fin de la seconde guerre mondiale et l'après seconde guerre mondiale.

Pourtant cette police des prix est censée avec pris fin depuis l'ordonnance du 1^{er} décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Dans son **article L410-2 du Code de commerce**, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Mais cette liberté tarifaire connaît de nombreuses dérogation ; mais cette police des prix n'a pas disparu depuis 1990 mais a été restreinte à certaines hypothèses

Le droit positif identifie les marchés susceptibles d'être régulés en matière tarifaire.

Section 1. Les marchés susceptibles de réglementations tarifaires

Les dispositions qui dérogent au droit commun du droit de la concurrence → les marchés que l'on peut réguler sont des marchés dits défaillants, où il n'y a pas de jeu de la libre concurrence → des marchés où il n'y a pas de structure concurrentielle. C'est la première hypothèse de la régulation tarifaire

Paragraphe 1 : les marchés dits défaillant

Un marché défaillant est un marché sur lequel on constate une absence de concurrence qui peut résulter de la structure même du marché (A), mais aussi de circonstances particulières (B).

A. La police des prix en cas de défaillance structurelle d'un marché

L410-2 alinéa 2 du Code de commerce : il évoque les secteurs dans lesquels la concurrence par les prix est limitée, soit par des textes, soit par une situation de monopole, ou encore qui peut résulter de difficulté d'approvisionnement

→ Prix de l'autoroute, de transfert d'énergie, de l'accès au transport ferroviaire.

En 2006, le CE, dans la décision **société des ciments antillais** a mis une régulation tarifaire en raison d'une simple position dominante → cette solution qui est très souple pour la puissance publique a été admise.

Il en va de même si la défaillance du marché est simplement conjoncturelle

B. La défaillance conjoncturelle du marché

L410-2 alinéa 3 du Code de commerce : la défaillance de ce du marché est liée à des circonstances extérieures comme une situation de crise, de calamité publique. Dans l'hypothèse de situations manifestement anormale du marché dans un secteur. Dans un telle hypothèse le gouvernement pourra prendre des mesures temporaires pour lutter contre la hausse des prix.

Le Code de commerce va imposer un décret en CE et non par décret simple pour procéder à une police de prix.

Exemple → bouclier tarifaire énergétique.

Paragraphe 2 : la réglementation tarifaire dans l'IG

Le Code de commerce nous indique dans **l'article L410-2** que les prix sont libres sauf si la loi en dispose autrement → cela signifie qu'il peut exister des régimes spéciaux en matière de réglementation tarifaire → des polices spéciales des prix.

Par exemple : le prix des médicaments. Le tabac est aussi encadré.

Section 2. Le niveau du tarif réglementé

Le régime de ces actes de réglementation tarifaire est presque commun, que le secteur soit concurrentiel ou non. Le DUE impose des contraintes quant au niveau des tarifs.

Ces règles de fond tiennent sur plusieurs aspects : -Un acte de régulation tarifaire doit respecter le ppe d'égalité devant la loi : il ne doit pas remettre en cause l'égalité de concurrence entre les opérateurs du secteur. Cela implique en outre selon les juridictions de traiter de manière identique les bénéficiaires de ces tarifs. Le ppe d'égalité est contrôlé par le JA. Le JA n'exerce qu'un contrôle restreint sur les tarifs pratiqués au regard du ppe d'égalité. Il effectue un contrôle de la disproportion manifeste : il vérifie que le tarif n'est pas disproportionnellement manifeste au regard de l'objectif visé.

-Si la régulation tarifaire s'applique dans le domaine d'un SP, les règles relatives au SP doivent s'appliquer et notamment les règles de redevance pour service rendue = **CE, 2007** : la redevance doit être proportionnée au coût du service, elle peut aussi tenir compte de l'avantage spécifique procurée à l'opérateur. Cela signifie que l'on peut fixer la redevance en fonction du chiffre d'affaires de l'opérateur. Ce n'est pas forcément objectif.

-Doit respecter le droit du marché et donc les règles de concurrence opposable à la puissance publique. En d'autres termes, cela ne peut pas placer un opérateur dans une situation anticoncurrentielle et le juge exerce un contrôle sur ces tarifs depuis 2004 (= **CE, 2004, Unidem**).

Le droit de la concurrence est plus exigeant.

La question de la réglementation tarifaire dans les secteurs récemment ouverts à la concurrence ?

= dans ces secteurs ouverts à la concurrence par le DUE. La puissance publique peut fixer le prix du timbre par exemple donc la régulation tarifaire est encore admise par le DUE mais elle est très encadrée. Le DUE impose une condition quant au niveau des tarifs réglementés dans le domaine des secteurs récemment ouverts à la concurrence. Dans ces secteurs la concurrence ne fait que se développer ce sont des secteurs qui pendant longtemps ont été dominés. Ils sont dans une optique de développement de la concurrence.

La CJUE a jugé en 2007 que le niveau des tarifs réglementés ne doit être inférieur au coût supporté par l'opérateur

Confirmé par **CJCE, 2010, Feder Utility** : c'est le ppe de l'orientation des tarifs

Exemple : En matière énergétique en 2008

= époque pendant laquelle EDF dispose du réseau d'énergie et vend aussi à des particuliers.

Question du coût d'accès au réseau ?

Le coût d'accès au réseau est un monopole donc c'est le gvt qui fixe le tarif. Si le gvt fixe des accès au réseau extrêmement élevés : Si on le vend à 10 et EDF supporte un coût d'accès de 3. Si le gvt dit que si on n'est pas EDF on doit payer 12 cad plus que le tarif de l'énergie.

Il y a 10 ans se sont posées des questions sur le prix de la fixation du prix de l'énergie :

Si le CE annule un arrêté tarifaire (= annulation rétroactive). En d'autres termes il est possible que le CE remette en cause plusieurs années de tarifs.

C'était un contentieux à plusieurs milliards d'euros.

Chapitre 2 : La question du droit interne des aides aux activités économiques

Une aide c'est ce que l'on peut considérer comme étant tout avantage conféré par une collectivité publique à un opérateur économique → une telle aide vise à soutenir le marché, elle peut avoir des objectifs très variés : de préserver le tissu économique si l'entreprise est en difficulté, elle peut avoir pour objet de préserver l'emploi.

Une aide peut avoir une contrepartie mais ce n'est pas systématique. Une aide en droit français est une subvention au sens du droit administratif → subvention définie par la loi du 12 avril 2000.

Une aide est un avantage encadré par le droit. D'abord, ces aides sont évidemment encadrées par le DUE. Cette aide doit rentrer dans le cadre législatif du DUE →

Le DU des aides permet de préserver la concurrence sur le marché → ce n'est pas l'objet du droit interne des aides qui n'encadre que les aides des collectivités territoriales dont le régime a été modifié dans le début du XXIème siècle.
→ Articles L411-1 et suivants du CGCT

Ces dispositions opèrent une répartition des compétences entre collectivités, ce qui permet de délimiter le régime général des aides locales économiques

Section 1. Le dispositif général d'aide locale à l'entreprise

Aujourd'hui, on trouve dans la loi concernant ce dispositif général, une indication des collectivités compétentes pour délivrer ces aides

Paragraphe 1 : Les autorités compétentes pour délivrer les aides

Au niveau local, l'autorité qui dispose d'une compétence de principe pour délivrer une aide est la région, ce qui n'exclue pas que d'autres collectivités peuvent délivrer des aides → la commune ou le département

A. La région

Elle dispose d'un rôle central qui a été clairement consacré en 2015 par la loi LOTRE qui est venue conférée aux régions cette compétence de principe pour définir ces aides aux entreprises.

CGCT → Le Conseil régional est exclusivement compétent en la matière.

Mais cette compétence exclusive de la région nécessite quelques remarques :

- Peu importe la forme de l'aide, puisque l'aide est souvent une subvention, mais ca peut également être tout avantage pour l'opérateur économique : prêt avantageux ; services ; avance remboursable proposée par la collectivité
- Ces pouvoirs de la Région s'exercent dans la limite de ceux de l'État. Le législateur exige que les aides soient compatibles avec les orientations de

l'État → mais les décisions de l'État sont très peu formalisées donc c'est difficile de dégager les orientations

- La région plus encore définit les orientations en matière de développement économique, orientations définies dans un schéma (SRII) → Schéma qui définit les orientations en matière d'aide des entreprises, qui devra être respecté par toutes les personnes publiques qui devront verser une aide aux opérateurs économiques. La région détermine l'orientation de la politique d'aide en matière régionale

Mais les communes disposent de compétences partielles

B. Les compétences résiduelles des communes

Ces communes peuvent-elles mêmes passer une convention avec la région qui leur permettent de participer au financement d'aides.

En outre, le CGCT indique que le conseil régional peut déléguer sa compétence à la commune.

Surtout que les communes disposent de compétences propres en matière économique → compétences qui sont listées à l'article L2251-2 → donne compétence aux communes lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique

Ceci étant cette hypothèse ne concerne que certains domaines : aide à l'immobilier de l'entreprise, les garanties d'emprunt, l'octroi d'aide aux professionnels de santé et zone déficitaire.

Les départements → Disposent de très peu de compétences en matière d'aides

Mais par rapport à la compétence communale, les compétences communales peuvent être transférer à des EPCI ou à des métropoles. En effet, en droit commun des métropoles il est considéré que c'est aux métropoles d'exercer les compétences en matière de régulation de l'économie à la place des communes membres.

Paragraphe 2 : Les conditions d'octroi des aides

Elles sont assez nombreuses :

Le DUE oblige à la notification des aides à la Commission européenne → cette obligation pèse sur l'État français. Cela étant, pour pouvoir remplir cette obligation, les collectivités doivent d'abord notifier à la l'État français ; mais surtout si l'aide locale se révèle illégale, c'est la collectivité qui en supportera les conséquences et qui supportera une éventuelle condamnation par le juge de l'UE.

A. L'objet des aides

Dans le CGCT, la solution est systématiquement la même : l'aide accordé au niveau local ne peut avoir que pour objet la création ou l'extension d'activités économiques

Cela signifie simplement que l'aide à un opérateur économique ne peut avoir que cet objet là et que dès lors qu'elle a cet objet, l'œuvre sera soumise à la législation interne relative au droit des aides.

En d'autres termes, seuls les aides aux opérateurs économiques sont encadrés → a contrario, les aides non économiques ne sont pas soumises à l'encadrement du droit des opérateurs économiques, elles sont libres

1. Les aides non économiques

Elles doivent respecter la compétence des autorités qui l'octroi ; et surtout doit être attribué avec une contrepartie suffisante selon le juge → obligation posée en 2009 par le CE, décision commune de Mère.

Par conséquent, l'aide non économique ne pose jamais de difficulté → dans une telle hypothèse il est tout à fait possible de donner cette aide sans avoir à respecter d'obligations particulières.

2. Les aides économiques

Ses conditions d'octroi ont été posées par un arrêt du CE, 2005, Commune D'Argentan : pose 3 conditions pour l'octroi d'une aide économique :

La condition relative à l'objet des aides :

- Il faut qu'elle soit octroyée dans l'intérêt public
- Il faut qu'elle réponde à un besoin local de la population
- Il faut qu'elle respecte la neutralité du SP

Le juge va apprécier assez soupagement l'intérêt public local qui peut parfois être extraterritorial → une activité de transport entre une archipels par exemple

B. Les bénéficiaires des aides

D'abord, le principe est celui qu'on a déjà abordé → celui selon lequel les aides économiques sont attribués à un opérateur économique, cad une entreprise, seuls ces aides délivrés aux opérateurs économiques sont soumises aux règles spéciales du CGCT ; par conséquent, les aides pas distribués aux entreprises ne sont pas soumises aux conditions du CGCT, à la législation du CGCT.

Cela implique plusieurs remarques :

- Il n'est pas possible de donner des aides aux personnes physiques. C'est prohibé sauf dérogation et en principe une aide n'est attribuée qu'aux personnes morales
- Les aides délivrées aux associations : l'association n'exerce pas non plus d'activité économique et par conséquent l'aide n'est pas soumise au régime du CGCT → Arrêt de section 2007 du CE, Commune d'Aix en Provence → dans laquelle le juge confirme qu'une association n'est pas une entreprise et que par conséquent elle ne peut pas être soumise au régime contraignant du CGCT.

- Concernant les aides aux personnes publiques, elles peuvent être octroyées d'une PPB à une autre PPB → dans cette hypothèse, soit la PPB exerce une activité économique, dans ce cas-là l'aide sera soumise au régime du CGCT ; à l'inverse, il est tout à fait possible pour une PPB d'accorder une aide à une autre PPB qui n'exerce d'activité économique → le régime du CGCT ne s'appliquera donc pas.
→ Ces aides entre PPB sont souvent attribués contractuellement, des contrats qui engagent leur signataires respectif → si une PPB s'engage à accorder une aide, elle doit le faire ; si elle ne le fait pas, elle pourra engager sa responsabilité contractuelle.

Affaires Rhône-Alpes → le TA Lyon a engagé la responsabilité de la région pour non-versement des aides à des communes.

Concernant le bénéficiaire de l'aide, il peut être un cocontractant de la PPB ; il arrive fréquemment qu'une telle aide soit prévue dans le cadre d'un contrat de la commande publique, surtout dans un contrat de concession de SP.

Distinction entre ce qui relève d'un contrat de la commande publique et un simple contrat de subvention/d'aide. Certains contrats sont conclus comme étant un contrat de subvention alors qu'en réalité ce sont des contrats de la commande publique → ces distinctions posent d'autant plus de difficultés quand l'aide est accordée en contrepartie de prestation de l'opérateur économique s'analysant en des contreparties contractuelles.

La distinction entre ces 2 contrats a été opérée pour la première fois dans un **avis du CE de 2004, l'avis cinémathèque française** → dans lequel le juge va dégager des indices qui permettent de distinguer les 2 contrats :

- Le premier indice est l'initiative du projet, de l'activité en question → si l'initiative est publique c'est plus vraisemblablement un contrat de la commande publique
- La réalisation d'une prestation de service pas l'organisme aidé
- Le juge va s'intéresser au lien direct qui peut exister entre la prestation de service réalisée et d'autre part le montant de la subvention. → si le montant correspond à la prestation de service alors forte chance que le contrat répond à un besoin de la PPB et donc que c'est un contrat de la commande publique.

Cette distinction est importante car si on est une personne publique et on maquille un contrat de la commande publique en contrat de subvention (on évite toutes les règles de la passation du contrat) → il y aura une violation du droit de la commande publique. Violer le droit de la commande publique conduit à la mise en cause pénale (délit de favoritisme). → Un maire qui ne donne pas la bonne qualification peut se faire poursuivre pénalement

Exemple, **CE 2011, Commune de Six-Fours les plages** : pour organiser un festival de musique dans la commune, la région avait versée une subvention qui doublait l'abandon de recette au profit de l'association). Mais aucune mise en concurrence et évidemment un opérateur concurrent va contester le contrat devant le JA. En

l'espèce le CE va requalifier le contrat de subvention en contrat de marché public → le juge va se fonder sur les indices précités : l'initiative était de la commune, de plus il y avait une prestation de service réalisée et il y avait un lien direct entre le niveau de la subvention et la réalisation de la subvention.

Exemple, CE, 2019 → La maire de paris a voulu faire construire des passerelles donc en principe c'est un contrat de la commande publique mais la mairie de Paris a fait un appel à projet → le CE a donné une leçon de droit à la mairie de Paris et a dit que le contrat envisageait répondait à un besoin de la PPB, que c'était, nécessairement un marché public de travaux et donc la mairie a changé le contrat afin d'éviter une condamnation pénale

Section 2. Les dispositifs particuliers d'aide aux opérateurs économiques

Il y a certains dispositifs très utiles et très fréquent en pratique → les aides à l'immobilier d'entreprise et les garanties d'emprunt des personnes publiques

Paragraphe 1 : Les aides à l'immobilier d'entreprise

Elles ont été réformées en 2015 et sont aujourd'hui régies par l'article L1511-3 CGCT : une disposition qui précise quelles sont les PPB compétences en matière de ces aides. Dans cette matière, le principe est celui de la compétence communale, la commune est seule compétente pour définir les régimes d'aide et les attribués.

La commune pourrait très bien avoir été délégué cette compétence à un EPCI et donc ce sera ce dernier qui attribuera le régime d'aide. Il en va de même si la compétence a été déléguée à une métropole et donc il faudra vérifier si c'est la commune ou la métropole qui exerce la compétence en la matière

Ces aides peuvent être des subventions, mais elles peuvent également être des rabais sur des prix de vente de terrain du domaine privé, locations de terrain par la PPB ou peut aussi prendre la forme de crédit-bail à des conditions là encore plus favorables que celles du marché → elles font nécessairement l'objet d'un contrat entre la personne publique et le bénéficiaire

Paragraphe 2 : les garanties d'emprunt des PPB

Ces garanties d'emprunt peuvent être accordées par les régions et les communes, le département n'a pas de compétences en la matière.

Pour les communes les compétences sont prévues à l'article L1252-1 CGCT

Pour les régions → L4453-2 CGCT

Il s'agit d'un cautionnement qui vient garantir le prêt contracté par une PPV → la PPB ne peut garantir que des emprunts, ce n'est qu'un prêt bancaire qui peut être garanti et pas d'autres financements de l'opérateur.

Mais quand une PPB garanti un emprunt elle encourt un risque de défaillance et c'est pour cela que le CGCT a posé 4 règles jurisprudentielles qui s'imposent aux PPB :

- Règle concernant le montant total des engagements garantis par la collectivité → ils ne peuvent pas dépassés 50% des recettes réelles de la collectivité.
- **2ème règle** : le CGCT pose une règle de répartition des risques et selon cette deuxième règle, le montant des annuités garanties et limitée à 10% pour un emprunteur
- **La 3ème règle** concerne l'emprunt garanti → la collectivité pas garantir plus de 50% de l'emprunt de l'emprunteur
- **4ème règle** : le CGCT prévoit qu'un cas de défaillance de l'emprunteur la collectivité puisse rembourser selon l'échéancier qui avait été accordée à l'emprunteur, un remboursement progressif pour éviter une charge trop lourde d'un coup

La forme de ces garantis → il n'y a pas d'exigence de passer une convention et seule une délibération de la collectivité suffirait à. Dès lors qu'une subvention à une valeur supérieure à 23 000 euros, elle doit faire l'objet d'un contrat → en pratique il n'y a pas bcp de collectivités qui se passent d'un contrat.

Ce contrat aura très souvent une nature juridique particulière → ces contrats de garantis ou de cautionnement sont nécessairement l'accessoire d'un contrat principal qui est un contrat de prêt de droit privé → en l'application de la théorie de l'accessoire, le contrat de cautionnement ou de garanti aura la même nature que le contrat auquel il se rapporte → **Tribunal des conflits 1998, décision Miglierina**

Il y a d'autres régimes d'aides pour les entreprises en difficulté par exemple, mais on n'en parlera pas

Les régimes d'aides dont on a parlé sont délivrés par le biais d'exercice de PPP → le droit administratif s'applique donc à ces opérations

Section 3. L'application des règles du droit administratif général

On va revenir sur la décision qui octroie l'aide → accorder une aide implique de respecter les PGD et notamment le principe d'égalité des opérateurs économiques.

→ La problématique du retrait d'une aide.

On terminera par la question de savoir si une PPB peut être responsable du non d'une aide interne.

Paragraphe 1 : la décision d'octroi de l'aide

L'aide peut être accordée soit par le biais d'un acte unilatéral, soit par le biais d'un contrat. Mais, on doit faire 2 remarques immédiatement : si son montant dépasse 23 000 euros il faut nécessairement conclure un contrat, et puis, plus encore, il est considéré en JP que le contrat qui attribue une aide contient un acte unilatéral

d'attribution de l'aide → c'est une décision unilatérale qui prend une forme contractuelle.

C'est pour cela que le CE a considéré que la décision d'octroyer une aide est un acte unilatéral, c'est nécessairement un AAU, alors même qu'il serait inclus dans un contrat.

→ Cette idée résulte d'une grande décision du **CE de section, 2019, décision SAS royale cinéma**.

→ D'un point de vue contentieux, cela veut dire que l'on peut former un REP contre cette décision, même si la décision est contenue dans un contrat administratif → tout le contentieux de la légalité de la subvention est un contentieux en excès de pouvoir

→ le juge permet la requête de tous les requérants

→ Sauf dans l'hypothèse de la responsabilité de la PPB ou cela relève d'un recours en plein contentieux

La majorité du temps la PPB dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour attribuer l'aide

→ la PPB va donc auto encadrer ce pouvoir : notamment pour les aides attribuées par les régions, on trouve très souvent un règlement d'attribution des aides qui doit être respecté lors de l'attribution des aides. Ce règlement a en principe nature réglementaire, mais pas systématiquement → ils sont parfois qualifiés des lignes directrices qui n'ont pas de valeur réglementaire

→ La PPB peut subordonner l'attribution de l'aide à des conditions qui sont très souvent dans les stipulations contractuelles.

Le CGCT prévoit un contrôle des PPB et de l'État sur les organismes aidés qui doivent évidemment fournir à la PPB une copie de leur budget et de leur compte et qui doivent également justifier des dépenses effectuées auprès de la PPB.

Paragraphe 2 : Le respect des principes généraux du droit administratif

Parmi les PGD, il y a le respect de l'égalité, étant précisé qu'une aide va nécessairement favoriser un opérateur par rapport à un autre.

→ Le juge a validé les régimes d'aide au regard de ce principe d'égalité. S'il est possible de discriminer à opérateur par rapport à un autre, la discrimination est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au développement économique et qui permet donc de porter atteinte au principe d'égalité → **CE, 1984, arrêt Goulet**

Doit aussi être respecté le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (LCI) et notamment le principe de libre concurrence

Le CE a notamment jugé qu'une collectivité ne pouvait pas décider de prendre en charge une activité économique dans le seul but de bénéficier d'une aide de la part d'une autre PPB → la solution résulte d'un arrêt de **1985 du CE, décision Boussac saint-frère**

Enfin, même si il ne s'agit pas d'un PGD, la décision d'octroyer une aide impose le respect de légalité, mais qui n'empêche pas la régulation de certains vices → le CE considère que les vices de forme et de procédure ne conduisent pas

systématiquement à l'annulation de la décision de l'octroi de l'aide → ces vices peuvent être régularisés par l'auteur de l'acte, en cas de contentieux le juge n'annule pas la décision entachée d'un tel vice et va donner un délai à la collectivité pour régulariser son acte. → **CE, 2016, Commune d'Émerainville**.

Cette solution a été rendue pour des motifs liés à la sécurité juridique de l'opérateur aidé.

Concernant la décision, cette solution rejoint les nouveaux pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir. En excès de pouvoir le juge n'annule plus systématiquement les actes illégaux, il a trouvé des alternatives à l'annulation et la régularisation constitue une des alternatives à l'annulation.

Paragraphe 3 : La question du retrait de l'aide

Il va différer selon que l'aide ait été accordé par contrat ou par acte unilatéral

Aide accordée par contrat : le contrat va prévoir des obligations à la charge des entreprises aidées. Des obligations qui sont obligatoirement des obligations contractuelles. Il est évident que le non-respect de ces obligations va conduire la PPB à en tirer les conséquences → il y a notamment la possibilité de sanctionner le cocontractant ou encore la possibilité de résilier le contrat pour inexécution qui conduira donc au retrait de l'aide en question.

→ La résiliation du contrat est donc possible qu'en cas d'inexécution contractuelle du cocontractant.

→ S'est posée la question de la possibilité de diminuer le montant de l'aide → est-ce c'est possible ? dans une telle hypothèse, l'entreprise ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la PPB, mais seule une responsabilité quasi-délictuelle, responsabilité pour faute, pourra être mise en œuvre. → **CE, 2011, décision EARL le Patis maillet**.

Aide accordée par acte unilatéral : en 2019, le CE a considéré qu'une décision d'octroi d'aide est une décision créatrice de droit pour son bénéficiaire → elle ne pourra donc être retirée que pour certaines conditions restrictives :

- Il faut que l'acte soit illégal
- L'acte doit être retiré au maximum après 4 mois son édicton

La PPB ne peut pas retirer une aide légale lorsqu'elle a décidé de l'attribuer, sauf dans un cas : le juge considère que les droits ne sont acquis que lorsque ces conditions sont respectées. En d'autres termes, si l'opérateur ne respecte pas les conditions d'octroi d'aide, on considère que la décision ne crée pas de droit acquis et la décision peut être retirée à tout moment par la PPB → **CE, 2008, décision crédit coopératif**.

Paragraphe 4 : La responsabilité de la PPB

2 séries de situations bien distinctes :

- La PPB peut engager sa responsabilité dans certain cas lorsqu'elle refuse d'octroyer une aide, notamment lorsqu'elle refuse illégalement d'octroyer une aide.
- Mais la PPB va voir aussi sa responsabilité engagée du fait d'avoir effectivement versée une aide à une entreprise

A. La responsabilité en cas de refus illégal de verser une aide

Ce refus peut engager la responsabilité pour faute de la PPB. Reste à savoir dans quelles hypothèses son pourrait constater une telle faute de la PPB → la plupart du temps la PPBN dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer une aide et le juge qu'un contrôle très restreint sur la décision en question. Il est difficile de démontrer une faute de la PPB

Hypothèses qui peuvent engager les responsabilités pour faite de la PPB :

- Le non-respect d'une ligne directrice qui encadrerait l'attribution d'aide
- La promesse de verser une aide non tenue
- En matière de garantie d'emprunt, la PPB peut être responsable envers l'emprunteur. Mais la PPB peut aussi voir sa responsabilité engagée envers le prêteur qui pourrait aussi avoir subi un préjudice du refus illégal de garantie d'emprunt.

B. La responsabilité de la PPB en cas d'octroi abusif ou illégal d'une aide

L'aide qui est octroyée illégalement pourra évidemment être contestée en excès de pouvoir par les concurrents de l'entreprise aidée ; les contribuables locaux qui ont tjr intérêt a contesté une décision qui met une dépense à la charge de la collectivité (**Casanova 1901, CE**) ; mais aussi l'action éventuelle des créanciers et actionnaires de l'entreprise aidée, dans l'hypothèse d'une procédure collective de l'entreprise en question → cette hypothèse c'est l'hypothèse de l'octroi abusif d'une aide à l'entreprise en difficulté. S'est posée la question de savoir si les créanciers et les actionnaires pouvaient intenter une action en comblement de passif qui est une action de droit commercial (c'est celle qui s'applique aux gérants de fait des entreprises, certains requérants ont dit qu'en soutenant de manière abusive, la PPB devenait gérante de fait et devait combler son passif).

Peut-on appliquer le droit du commerce à la PPB, et devant quel juge rechercher cette responsabilité ?

A la première question, les juridictions ont admis qu'une PPB pouvaient être considéré comme gérante de fait et qu'une action de comblement de passif pouvait être intentée devant la PPB → admis par le **Tribunal des conflits en 1984, dans une décision préfet d'Eure et Loire**.

Mais cette action relève d'une compétence exclusive du juge administratif → **Tribunal des Conflits, 1999, comité d'expansion de la Dordogne**. Le juge des conflits va ici justifier la compétence administrative en indiquant que l'octroi d'une aide relève d'une

mission de SP, d'une mission de SP administratif et étant une mission de SPA, la mise en œuvre de cette mission entraîne la compétence du juge administratif → Ceci étant, dans cette décision, le juge va considérer que le juge administratif ne pourra appliquer que les règles du droit administratif et non pas les règles du Code de commerce. En d'autres termes, le juge n'applique pas directement les règles du Code de commerce mais construit un régime de responsabilité calqué sur l'action en comblement de passif, une action en responsabilité quasi-délictuelle qui a été mise en œuvre à plusieurs reprises → Exemple : **arrêt CE 2005, département de la Dordogne**, dans laquelle le juge administratif accepte cette action en responsabilité en s'inspirant des règles du Code de commerce

Chapitre 3 : La prohibition des aides d'État en DUE

C'est un régime qui s'applique à l'ensemble des PPB, y compris l'État donc → dans son principe le régime est clair → posé aux **articles 107 et 108 du TFUE**. Ces articles prohibent tout avantage octroyé par une PPB à un opérateur économique.

En d'autres termes, les aides sont en principe prohibées, mais on va constater que le traité prévoit un certain nombre de dérogation à ce principe.

Le droit des aides ne connaissait pas bcp de concrétisation au XXème siècle, mais au XXIème siècle le juge national applique concrètement ce droit des aides.

Section 1. La notion d'aide d'État

Une aide pour être qualifiée d'aide doit remplir 4 critères cumulatifs, soit la mesure remplit ces critères et ne peut pas être octroyée, soit c'est le contraire :

- Une aide est un avantage
- Un avantage qui provient des ressources de l'État
- Qui affecte les échanges entre EM
- Un avantage qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence sur le marché

Paragraphe 1 : L'avantage

En DUE l'aide est qualifiée d'un avantage pour son bénéficiaire, l'avantage c'est toute mesure qui vient alléger les charges d'une entreprise, peu importe la forme de l'avantage, ce qui est important c'est la forme anormale de cet avantage.

L'avantage peut être alloué, selon la Cour, sous quelque forme que ce soit ; il peut être une subvention, une exonération d'impôt, une garantie d'emploi, une cession de bâtiment à des conditions favorables, voire même une location à des conditions favorables, ou la fourniture de biens ou de services à des conditions favorables

Le DUE ne prend pas en compte seulement le versement d'argent

Mais en principe ne constitue pas un avantage la rémunération d'une prestation de service → il s'agit d'une rémunération et pas d'un avantage sauf si la PPB va accorder des conditions préférentielles à la PPV. Il a été jugé que l'avantage qu'offre

une entreprise publique à l'une de ses filiales peut être une aide d'État, notamment si l'entreprise publique met à disposition de la filiale des biens et services à des conditions préférentielles. Pour éviter la qualification d'aide, il suffit de mettre en place une rémunération convenable. → CJCE 2003, affaire Chronopost.

Dans la pratique, certaines PPB ont essayé parfois de masquer des régimes d'aide en prévoyant des contreparties factices à des subventions → elles n'empêchent pas la qualification d'aide → 2006, CE, Affaire Ryan Air → elle concernait les subventions accordées aux compagnies low-cost par les aéroports locaux. Le CE avait requalifié que les mesures étaient des aides d'État car la subvention n'a pas de contrepartie réelle donc il s'agit d'un avantage réel.

Paragraphe 2 : Un avantage anormal

Pour vérifier la normalité d'un avantage, la CJUE a recours à un test qui est le test des conditions normales de marché qui permet de vérifier si la mesure tend véritablement à aider un opérateur ou si cette mesure relève du comportement normal d'un agent économique et ordinaire.

Soit la mesure aurait pu être effectuée par un agent économique ordinaire, auquel cas elle n'est pas une aide ; soit elle n'aurait pas pu être effectuée par un agent économique ordinaire, auquel cas c'est une aide. → La Cour va vérifier si la mesure relève normalement ou non d'un agent économique ordinaire.

Il existe plusieurs tests → Test de l'investisseur normal

Enfin, tjr par rapport à cet avantage anormal, la mesure doit être sélective pour être qualifiée d'aide, elle doit être profiter qu'à certains opérateurs, il faut que l'aide soit qualifiée de sélective → une mesure générale ne peut pas être qualifiée d'aide

Paragraphe 3 : Les ressources d'État

La CJUE a dit que peu importe la PPB qui verse l'aide, cette PPB n'est pas limitée à l'État → celle-ci est imputable à l'État, il faut enfin que l'aide est une incidence sur les ressources de l'État.

A. La PPB attributaire de l'aide

Sur ce point on aurait pu avoir un doute, depuis les années 70, la CJUE nous a indiqué que les dispositifs de l'article 107 et 108 s'appliquent à toutes les personnes publiques, peu importe donc celle qui attribue l'aide.

Ce qui peut donc inclure dans certains cas les organismes contrôlés par les PPB ou financés par les PPB → on pense aux mesures versées par des entreprises publiques qui peuvent aussi être qualifiées d'aide d'État.

B. L'imputabilité de l'aide à la puissance publique

Condition qui signifie que la PPB doit avoir décidée du versement de l'aide. La Cour l'a appliqué dans une affaire qui concernait les campagnes publicitaires en faveur

des opticiens aux Pays-Bas → cela avait été décidée par un organisme professionnel et la Cour va considérer qu'en l'espèce le financement n'est pas imputable à la Puissance publique puisque ce n'est pas elle qui a décidé du versement de ce financement.

C. L'incidence de l'aide sur les ressources publiques

Pour être qualifiée d'aide d'État, la mesure doit soit aggraver les charges de la PPB, soit diminuer ses ressources. En d'autres termes, cela signifie qu'une mesure strictement juridique qui n'a pas de conséquences sur le budget de la PPB ne peut pas être qualifiée d'aide d'État.

Une difficulté s'est posée en 2004, dans une affaire qui a concerné une aide potentielle de l'État français à la société France Telecom → Précisément un projet d'avance d'actionnaire à bénéficier à la société France Telecom, le ministre avait mentionné ce projet dans les médias et cela eu des conséquences → le ministre a décidé d'abandonner son avance d'actionnaire quelques jours plus tard

→ en 2004, la Commission y a vu une aide dès lors que la mesure aurait pu engager les ressources publiques. Le Tribunal de l'UE a sanctionné cette approche en considérant qu'il n'y a pas eu de versement effectif d'avance actionnaire et qu'il n'y a donc pas eu d'incidence sur le budget de l'État.

Mais la **CJUE, en 2013, dans une décision Bouygues Telecom**, la Cour va considérer que le projet d'avance d'actionnaire était bien une aide d'État et la Cour va considérer qu'il n'est pas nécessaire que le budget soit immédiatement prélevé → il faut simplement que l'incidence sur les ressources de l'État soit potentielle et non réelle

Le CE a eu une approche différente → **Arrêt de 2012, arrêt CMN**, à propos d'un contrat de concession de SP et d'une stipulation de ce contrat qui permettait au cocontractant d'obtenir des financements additionnels en cas de Pour le CE la mise en œuvre de la clause n'est pas automatique, elle est subordonnée à une décision de la PPB et seul l'éventuelle décision de la PPB peut être qualifiée d'aide.

Enfin pour terminer sur ce sous critère, la question s'est encore posée si il pouvait y avoir transfert de ressources d'État en cas d'un transfert de ressource entre personnes privées → la question s'est posée quant aux régimes d'aides des énergies renouvelables → en droit des ENR, EDF a l'obligation d'acheter toute production d'énergie → dans une telle hypothèse, les 2 acteurs sont des personnes privées et pourtant la **CJUE y a vu, en 2013, une aide d'État, dans sa décision Vent de colère** → un personne entre 2 PPV peut aussi recevoir la qualification d'aide d'État

Paragraphe 3 : L'aide affecte les échanges entre les EM

La CJUE considère que les échanges doivent être affectés ou potentiellement affectés. Pour qu'il y ait une affectation des échanges potentielles, il faut que l'on soit en face d'une distorsion de concurrence. → Une aide est tjr une distorsion de concurrence, sauf si le marché n'est pas concurrentiel.

Une mesure locale peut affecter les échanges entre EM → une mesure d'aide à une piscine locale peut être qualifiée d'aide d'État parce qu'il empêche les opérateurs privés d'exercer cette prestation

Certaines aides qui sont relativement basses ne sont pas contrôlées et sont donc admises → ce sont les aides de minimis → un maximum de 300 000 euros sur 3 ans depuis 2023. En dessous de ce montant, l'aide n'est pas contrôlée et peut être versée sans qu'il n'y ait de conséquences

Paragraphe 4 : il faut que l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence

Pdt très longtemps les cours de justice ne contrôlaient pas cette condition → la CJ considérait que toute aide faussait la concurrence, mais pour démontrer cela il faut effectuer une analyse économique qui n'était longtemps pas affectée par les juridictions.

Mais désormais les cours de justice de l'UE effectuent cette analyse économique depuis **un arrêt de 2008, la décision Chronopost**.

Section 2. Dérogation à la prohibition des aides d'État

Plusieurs fondements dans les articles :

- 1^{ère} stipulation : Article 107 paragraphe 2 du TFUE qui évoque des aides compatibles de plein droit, c'est-à-dire des aides qui sont compatibles sans qu'il soit nécessaire de recevoir l'autorisation de la Commission européenne
- Article 107 paragraphe 3 TFUE Évoque les aides qui peuvent être déclarées compatibles par la Commission européenne
- 3^{ème} dérogation : **article 106 paragraphe 2 TFUE**

Paragraphe 1 : Les aides compatibles de plein droit

L'article 107 paragraphe 2 énumère 3 types d'aide :

- Les aides à caractère social
- Les aides destinées à remédier à des calamités ou des événements extraordinaires → exemple : Covid
- Il permet d'accorder de plein droit des aides de soutien aux anciennes régions de la RFA affectées par la division de l'Allemagne → ne sert plus à rien donc

Paragraphe 2 : Les stipulations du §3 de l'article 107 TFUE

Il évoque 4 types d'aide qui peuvent être déclarées compatibles :

- Les aides au développement des régions défavorisées
- Les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie
- Les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités
- Les aides destinées à la culture et à la préservation du patrimoine

Ces aides peuvent donc être déclarées compatibles à la suite d'une décision purement discrétionnaire de la Commission.

Paragraphe 3 : L'article 106 § 2 du TFUE

Cet article contient une dérogation à l'ensemble des règles du traité et pas seulement le droit des aides, en faveur des services d'intérêt économique général (SIEG) qui est une notion pouvant être rapproché du SP.
Le SIEG est une activité économique d'IG

Il faut donc que la dérogation aux règles du traité soit justifiée et proportionnée.
La dérogation au droit des aides est possible → les juridictions ont dit que oui.

Remarque sur les dérogations en droit des aides :

- Ils ont conduit à la mise en place d'une politique d'aide par la commission européenne. Il y a une politique publique en matière d'aide très évolutive.

Section 3. Procédure de contrôle de ces actes d'État

Distinction entre la compatibilité d'une aide et d'autre part la légalité d'une aide : face à une aide l'EM a l'obligation de notifier l'aide de la Commission européenne → en cas d'absence de notification, on va considérer que l'aide est illégale, l'aide illégale est l'aide non notifiée et peu importe ou non si l'aide est compatible avec les traités.

L'aide incompatible est celle qui a été notifiée mais celle qui est contraire aux règles du traité.

Le contrôle de la compatibilité de l'aide est effectuée par l'UE, alors que la légalité de l'aide est appréciée par les juridictions nationales

Xxx

A) Principe du contrôle du juge national

XXXX

Arrêt 1990 CE « fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires »

Ainsi il existe un contrôle du juge national, s'il considère **que l'aide n'a pas été notifiée**, elle est illégale et donc elle doit être annulée par le juge admin.

La notification d'aide à la commission est une décision qui relève des relations inter de la fr à **c'est un acte de gouvernement** et en principe ces actes ne sont pas susceptibles au recours. Or le CE **est revenu sur cette décision pour faciliter recours c/ aides illégales** : CE 2008 « CNIVAO », ici est jugé recevable un recours c/ un refus de notifier une aide illégale. Juge considère que **le refus** de notifier une aide n'est

pas un acte de gouvernement et donc il peut y avoir un recours. La décision de notifier une aide en elle-même demeure sinon un acte de gouvernement

Remarque : parfois ce sera le juge judiciaire qui devra apprécier si une mesure est une aide d'E : en principe il n'est pas compétent pour exam légalité de l'acte admin à arrêt « Septfonds », **SAUF SI acte admin c/r au DUE**, alors le juge judiciaire peut apprécier sa conventionnalité et donc sa régularité à jugement TC 2011 « SCEA du chenu ».

Bref, approche assez restrictive de la notion d'aide d'E par le CE. Aujourd'hui le CE rend encore des décisions qui ne sont pas vrmt respectueuses des notions d'aides de l'UE à juge national nationaliste mais bon pas besoin de retenir je crois.

B) Effets de l'illégalité de l'aide

L'aide illégale va évidemment être **annulée** au contentieux, mais l'annulation n'est pas la seule conseq, en DUE si l'aide est illégale **elle doit être restituée à la puissance publique**. Toutefois il y a qqs années certains contentieux sont apparus : l'Union impose qu'une aide d'État soit notifiée à la Commission avant sa mise en œuvre, selon l'article 108§3TFUE. Mais alors si une aide jugée compatible avec le DUE mais qu'elle n'a pas été notifiée à la commission avant sa mise en place, (ce qui est illégal) et qu'elle a été régularisée à posteriori (donc notifiée après), **est ce qu'elle redevient légale, et surtout est il nécessaire de restituer l'aide ?** C'est en réalité tout le contentieux de l'**affaire CELF** (grande affaire). Ici la CJUE considère que la compatibilité n'exclue pas l'obligation de restitution, (illégal ≠ incompatible visiblement)

1e volet de l'affaire concernant la restitution : Dans l'arrêt de la CJCE 2008 « CELF » le juge affirme **qu'il n'est pas nécessaire de récupérer une aide illégale en cas de décision définitive de compatibilité prononcée par la commission**. à Limite de cette décision : on parle bien d'une aide illégale, depuis sa naissance jusqu'à la décision de la commission affirmant qu'elle a été régularisée. Ainsi la cour exige que celui qui l'a reçue verse des intérêts au titre de l'aide illégale qu'il a reçu pendant cette période.

2e volet de l'affaire « CELF » CJUE 2010 le juge de l'UE est revenu sur sa décision et a jugé qu'en fait au vu des circonstances, l'aide est incompatible avec le DUE. En conséquence, le juge national (ici CE) se demandait s'il devait **suspendre** (**"surseoir"**) **la procédure de récupération de l'aide illégale** le temps que la Commission réexamine et rende une décision définitive sur la compatibilité de l'aide.

→ un juge national saisi d'une demande de restitution ne peut pas attendre qu'une nouvelle décision de la Commission soit rendue, **il doit statuer sans délai et ainsi recouvrir l'aide**.

Règles juridiques de récupération d'une aide illégale : 2009 « Viniflohr » à ici CE développe une **méthode** pour déterminer quelles sont les règles de récupération d'une aide

- Vérifier s'il existe des règles de récupération prévues par le DUE (c rare)
- Quand il n'y en a pas on applique règles de D nationales à condition qu'elles soient compatibles avec le DUE. Pour cela on vérifie si la règle n'est pas discriminatoire, et si elle ne rend pas excessivement difficile la récupération de l'aide.

- Ainsi en application du D national on fait **un retrait d'acte créateur de D** : il faut que l'acte soit illégal et que le retrait s'effectue dans les 4 mois suivant la prise de décision.

Reste à savoir si ces règles sont compatibles avec le DUE. Pour le CE en 2009 les règles de retrait d'acte admin créateur de D sont compatibles avec le DUE alors qu'on aurait pu avoir un doute vis-à-vis de la durée de 4 mois qui pourrait peut-être être considérée comme un peu courte car parfois l'admin est lente et du coup ça rend difficile le fait de récup l'aide.

Chapitre 9 : La régulation des marchés

Chapitre ou on va faire de la théorie du D pour savoir si la notion de régulation est de D positif ou pas

La régulation qui est une notion de mécanique ou de physique vise l'équilibre d'un système complexe, mais dans le domaine juridique, il n'y a pas de def exacte de ce que serait la régulation. Ainsi on a pu se dmd si c'était vrmt une notion de droit ou si elle n'était qu'une notion du discours sur le D (=doctrine).

Ce n'est pas encore une catégorie juridique du D adm car on ne lui associe pas de régime particulier. Cela étant cette notion demeure très importante du discours sur le D et qui permet de comprendre une sorte de renouvellement du rôle de la puissance publique. En ce sens il existe aujourd'hui une police spéciale de la régulation des marchés.

Section 1 : notion doctrinale de régulation

En droit positif la notion n'étant pas identifiée est donc très peu présente. Mais depuis qqs années le terme de régulation est pas mal utilisé par la doctrine. Ainsi elle dvpt une proposition doctrinale dans les années 2000 qui vont dans 2 sens distincts. Certains auteurs ont tenté de la définir mais d'autres ont construit des théories doctrinales autour de cette notion.

I. Définitions doctrinales de la notion de régulation

Ces définitions ne convergent pas, il y en a plusieurs.

A) Les autorités de régulation

Définition institutionnelle, conception adoptée par les 1ers auteurs et notamment Jacques Chevaliers. Pour eux la régulation renvoie **à des autorités admin particulières et notamment les AAI** → ainsi **régulation = intervention de l'E par le biais des AAI**. Mais en D positif on constate qu'il y a certes des ministres qui les exercent (autorités non indépendantes), mais aussi des prs morales de droit privé, ainsi la conception qui lie régulation et autorité indep est fausse et c un échec du coup on cherche une autre vision à

B) La fonction de régulation

Selon cette conception la régulation serait **une nouvelle fonction admin** à côté du service public et de la police qui sont les 2 principales fonctions de l'admin, et ça viserait à **garantir l'équilibre d'un secteur d'activité, ou d'un secteur éco**. Cette conception est celle de Bruno Lasserre par exemple, et elle semble compatible avec le D positif. Par exemple le secteur des communications électroniques, l'ARSEP, selon la loi il dispose d'une fonction de régulation qui vise à promouvoir la concurrence et **concilier** cet impératif avec d'autres impératifs d'intérêt général.

Cela étant, cette fonction de régulation n'est pas propre aux autorités de régulation, c'est une fonction qui relève aujourd'hui de toute autorité admin. La concurrence est un élément de l'activité G par ex ainsi il est impossible d'id une fonction de régulation propre à une autorité admin.

C) Les pouvoirs de régulation

Ici la régulation renvoie à **des pouvoirs et prérogatives particulières**. Thèse de *Laurence Calendri* à renvoie à des pouvoirs admin particulières qui n'appartiendraient qu'aux autorités de régulation et qui seraient très originaux par rapport aux autres autorités admin. Ce serait le pouvoir d'édicter du D souple qui serait en qq sorte l'identification de la régulation.

Conception critiquable à jurisprudence ferveur et numérisable sur les autorités de régulation puis arrêt Lepen qui dit que le D souple peut être édicté par n'importe quelle autorité admin ni de régulation ni indep

Ainsi ces définitions sont un échec d'un pov doctrinal, elles ne sont pas conformes au D positif, et en tant que juriste seul le D + nous concerne
D'autres auteurs n'ont pas souhaité def cette notion mais construire des théories dessus

II. Les théories doctrinales fondées sur la notion de régulation

A) Le « droit-régulation »

Ici la régulation serait selon Gerard Timcit **un nouveau type de D** qui vise les modes d'action **souple** et informels, ce serait un autre D qui n'est pas un D réglementaire
C un peu choquant psk le D souple c pas du D il ne relève pas de la norme juridique.

B) Le « droit de la régulation »

Selon cette théorie la régulation **serait une nouvelle branche du D**. Ce serait un droit spécial qui est distinct du D com1. Ainsi il y aurait nécessairement des activités indep, cette branche serait différente du D de la concurrence et servirait à construire de la concurrence sur certains marchés. Cette conception voit la régulation comme branche du D, or on ne peut id une branche du d par son simple objet selon Odel (?)
à pour id une branche du D faut id des règles spécifiques et originales du Droit commun, or la spécificité du D de la régulation est impossible à identifier.
→ Pas de régime juridique particulier attribué au D de la régulation.

C) L' « Etat régulateur »

C'est une notion de science po à la base, Majone, ouvrage de 1996 à régulation serait une nouvelle forme **d'intervention de l'E dans l'éco** qui serait à moitié entre l'E interventionniste et libéraliste. → neutre pour la concurrence.

Ne vise pas à id des règles nouvelles en D, Conception de la régulation selon le prof : ce n'est qu'une police spéciale

Section 2 : La police spéciale de la régulation des marchés

Le D positif id **une mission de police spéciale** qui relève de la régulation. C ce que disent plein de décisions de justice sur l'autorité de la concurrence. Selon le CE elle exerce un pouvoir de police genre c une police des marchés, et en effet elle comprend tous les éléments d'une police spéciale.

Pour distinguer police spé de la police G : police spé exercée par des autorités particulières (PM, maires, préfets), et elle vise très souvent une finalité diff de la police G et qui n'est pas limitée à l'op mais peut viser tout intérêt général, et elle est aussi encadrée par un texte spécifique qui prévoit de procédures qu'on ne retrouve pas en police G

====→ tous ces indices se retrouvent en matière de régulation : elle vise l'objectif de préserver et développer la concurrence sur le marché, et elle est systématiquement encadrée par des lois spéciales et spécifiques à chaque secteur de l'économie. → la régulation est une police spéciale qui régule les marchés économiques. Elle est spécifique à chaque marché ainsi il existe peu de règles générales en matière de régulation.

Elle renvoie aujourd'hui à une intervention amin qui renvoie à un régime de D admin assez générale à c'est une fonction originale avec un régime basique

Chapitre 10 : Les autorités de régulation des marchés

AAI et API

Il n'existe pas un modèle d'autorité de régulation, ce qui est certain à l'inverse c que la plupart des autorités de régulation sont indep aujourd'hui. C'est par ex l'autorité des marchés financiers (API), l'ACRE et l'ARSEP...

Section 1 : L'indépendance de l'autorité de régulation

Rappels : pour id l'indep d'une AAI, on prend en compte l'absence de hiérarchie admin et ministérielle. Un ministre n'est pas le chef de svc de l'autorité indep et ainsi on ne peut pas lui donner d'instructions.

AAI n'a pas de personnalité morale car elle relève de la perso morale E, et l'API dispose de la prs morale, elle est ainsi responsable sur ses propres deniers de ses actions.

I. Les fondements de l'indépendance

C'est ce qui justifie cette indep.

A) Séparation de fonctions en DUE

C'est une exigence du DUE de la concurrence qui propose séparation des fonctions d'opérateur et de régulateur. (Non cumul des fonctions). Principe dégagé des les années 1990 et interdit de déléguer à un opérateur éco une fonction de réglementation des marchés à un opérateur éco à CJCE 2008 « motoe », confirmé et précisé en 2023ds CJUE « Superligue »

→ Dans l'arrêt motoe était en cause une réglementation nationale qui confiait orga de course de moto à un opérateur privé qui en organisait déjà. --- jsp mais il y a eu cumul et c'est un abus de position dominante selon l'ue

→ Dans l'affaire superligue : en 2023 les grands clubs euro ont dmd à l'UEFA d'autoriser une grande compétition, mais l'UEFa est un opérateur éco c'est une entreprise qui participait à un pouvoir règlementaire, et du coup elle ne pouvait pas refuser dans les conditions dans laquelle elle l'a fait

B) Neutralité et efficacité de la régulation

Avoir un régulateur indep est + efficace en pratique. Cette efficacité se justifie par l'absence de politiques qui viendraient troubler l'action. à les actes admin dans ce domaine relèvent exclusivement d'autorité admin indep donc ces secteurs sont sortis de l'activité pol aujourd'hui. C'est la conseq de la régulation indep, elle est plus efficace car pas politique mais à a fois c pas super psk ne fait pas l'objet de politiques pb

Mais efficacité résulte aussi de leur neutralité, qui est une garantie pour les opérateurs éco du secteur. En pratique autorités acceptent plus facilement ordre d'un régulateur indep que d'un ministre.

II. Les difficultés démocratiques soulevées par l'indépendance

Du pov de l'E de D, un régulateur indep pourrait poser une difficulté :

Le principe démocratique implique l'E de D = soumission de l'admin au D , mais ça implique aussi selon le pov C° un contrôle du gouvernement notamment par sa resp devant l'AN art 20 C°.

Or les AI sont hors hiérarchies, elles ne sont pas sous contrôle du gouvernement, par conséquent il n'existe pas de resp politique des AAI, elles sont soumises à la loi et contrôlées par le juge mais elles ne sont pas soumises à un contrôle

Attention ça veut pas dire qu'elles sont antidémocratiques, le parlement peut quand même contrôler la nomination de ces autorités, ainsi que recevoir un rapport sur l'action de ces autorités. De plus maintenant il peut aussi supprimer un régulateur s'il le souhaite donc oui en soit maintenant il y a une resp du régulateur devant le pmt. (ça c en théorie mais en pratique ça pue la merde le parlement ne supprime pas les régulateurs mais juste les renomme ????)

III. Les modalités de l'indépendance

XXX

L'indépendance dépend des moyens matériels et humains du régulateur à indépendance organique qui est largement variable suivant les autorités de régulation

Choses que font varier leur indep :

A) Les formes juridiques des régulateurs

D'abord consacrés sous la forme d'AAI dans les 90s, puis sont apparues les API (qui à la diff des AAI ont une personnalité morale). Par ex : l'autorité des marchés financiers à dès 2003 été consacrée comme une API.

Cette distinction entraîne des conséquences juridiques, et notamment quant aux moyens des autorités en cause à API mieux dotées que les AAI car leurs missions sont un peu plus importantes. Mais d'un pov strictement juridiques, le choix que la structure soit AAI ou Api est un choix du légi et n'a pas forcément toujours de cohérence. Non seulement l'AI peut-être admin, ou publique, mais elle peut aussi être privée (Autorité privée indep de régulation) à on peut confier mission de régulation à des prs privées et même à des assos.

Depuis 2008, il y a une autorité indep inscrite dans les textes C° → le défenseur des droits, c'est une autorité indep garantie par la C°, mais cette appellation n'a pas de conseq sur cette autorité, elle est admin.

B) Eléments C°ls de l'indépendance

L'indep d'un régulateur dépend largement de **sa compo interne** et notamment de ses collègues, et de la nomination des présidents des autorités de régulation. Leur seul élément non variable c'est la nomination du président des régulateurs nommés par décret du chef de l'E, puis verif par commission parlementaire art 13C°. Ce qui est plus variable c'est le **nombre de membres du collège** mais **aussi l'influence de l'exécutif** dans la nomination de ces membres.

L'indep est aussi assurée par la durée du mandat de ses membres qui peut aussi varier, plus la durée est longue plus l'indep est forte, en général la durée du mandat est de 5ans + ils sont irrévocables afin de garantir leur indep.

L'indépendance des régulateurs dépend aussi de xxx --- indep organique
Depuis 30ans il est constant que sont nommés au sein de ces collèges des personnalités qualifiées qui ont beaucoup de compétences professionnelles dans ces secteurs. Or cela pose un vrai pb de conflit d'intérêts au regard du D+. Par exemple si on nomme dans un collège de régulateurs qq qui a beaucoup bossé dans ce secteur on pourrait le soupçonner de toujours soutenir son ancien employeur → loi sur la transparence de la vie pb en 2013 apporte des solutions, il faut ainsi respecter un délai entre les fonctions privées et les fonctions de membre régulateur, + contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie pb et qui peut s'opposer à une nomination si elle soupçonne un conflit d'intérêts
Mais bon ça reste quand même assez délicat car seuls ceux ayant travaillé dans ces marchés savent comment ils fonctionnent.

L'indépendance fonctionnelle elle renvoie aux moyens des régulateurs, moyens qui sont très variables d'une fonction à une autre ex l'ADOPI est l'ancienne autorité qui poursuivait les téléchargements illégaux et ils avaient 6 agents pour toute la fr donc impossible de tout surveiller, contrôlaient 1/10 des téléchargements et autorité supp psk viole le principe d'égalité devant la loi

Section 2 : Les pouvoirs variables des autorités de régulation

Ils cumulent plusieurs types de prérogatives, et cette cumulation varie en fonction de l'autorité de régulation.

I. Le cumul des pouvoirs des autorités de régulation

Ce cumul pose des problèmes au regard de la C° vers les années 1980, certains estimaient que ça violait le principe de la séparation des pouvoirs du fait du cumul de certains pouvoirs réglementaires utilisées en même temps qu'un pouvoir d'exécution, ET de sanction admin → c'est le même organe qui crée la norme, l'applique et sanctionne son non-respect.

CC° en 1980 valide ce cumul des pouvoirs et estime qu'il ne porte pas atteinte à l'art 16DDHC qui pose ce principe de séparation. En effet elle n'est jamais hermétique cette séparation et n'exclue pas une collaboration. → « loi relative à la transparence des marchés financiers » CC°1989

Mais du coup quels pouvoirs peuvent être attribués aux régulateurs ?

- Il y a **un pouvoir d'influence** : tant auprès de l'exécutif qu'auprès des opérateurs du secteur, tous ces régulateurs disposent d'un pouvoir d'avis qui impliquent qu'ils doivent donc être consultés sur certaines décisions ministérielles.

Ils ont le pouvoir d'édicter du D souple (recommandations, lignes directrices etc) ce D est quantitativement très important chez les régulateurs à il permet d'édicter des normes au quotidien et d'édicter des normes dans un délai très court et de faire évoluer leur interprétation. Les régulateurs n'ont pas tous les mêmes pouvoirs et la plupart n'ont pas vrmt de pouvoir réglementaire et du coup le droit souple compense cette absence.

- **Pv réglementaire**, confié aux régulateurs les plus importants tels que l'autorité des marchés financiers ou encore l'ARSEP. Mais c'est un pouvoir quand même relativement limité aux champs de compétence du régulateur.

- **Pouvoir de décision individuelle**, ici ils disposent d'un pouvoir original dit « quasi juridictionnel » qui permet au régulateur de trancher des différends dans des litiges entre deux personnes privées. Assez analogue au pouvoir d'un juge judiciaire, alors il y a une déjudiciarisation de certains contentieux psk du coup ça repartit les litiges. C'est principalement sur le contentieux de l'accès au réseau et alors le régulateur statue dans des manières particulières. Ce pouvoir n'appartient qu'aux régulateurs sectoriels qui n'interviennent que dans un secteur de l'économie

- **Les pouvoirs de sanction admin doublé d'un pouvoir d'enquête** : confié à ceux qui sont très compétents dans ces matières là à enquêtes et qui peuvent déboucher sur des sanctions. Ils peuvent sanctionner mais leurs sanctions ne peuvent pas être trop importantes elles peuvent être dissuasives par exemple. Mais quand tu veux sanctionner un très gros opérateur du secteur, Meta ou Google par ex tu leur met une sanction de 100k c'est rien pour eux du coup c'est pas si dissuasif à du coup on augment un peu le pouvoir des sanctions dissuasives.

II. L'encadrement du cumul des pouvoirs par les régulateurs

Juges C° et euro se prononce sur le pouvoir de sanction et pouvoir réglementaire de ces régulateurs. Le pouvoir de sanction a beaucoup évolué depuis 30ans,

A) Encadrement du pouvoir réglementaire

Attribution d'un pouvoir de régulateur validée par le CC° en 1989 dans la même décision sur la transparence. Ici le CC° juge que l'art 21 C° ne s'oppose pas à la délégation d'un pouvoir réglementaire au régulateur même si dans l'art il est dit que le pouvoir appartient au PM, donc oui c'est autorisé mais il y a une exigence c°lle de limitation, tant concernant le champ des mesures prises que leur contenu

B) Encadrement du pouvoir de sanction

Existence validée au regard de la C° par le CC°, dans une limite : celle des peines privatives de liberté → seul un juge peut prononcer une peine d'enfermement ainsi les régulateurs peuvent seulement prononcer des sanctions pécuniaires. Mais ce pouvoir de sanction pose des difficultés notamment pour le D à un procès équitable qui implique l'impartialité de l'autorité de décision.

Quand on parle d'autorité de régulation ce n'est pas un juge mais une autorité admin. Les D de la défense tels qu'imposés en matière pénale sont retranscrits dans le cadre des sanctions admin, c'est ce qu'a jugé la CEDH qui a considéré que les AI sont des juridictions au sens de l'art 6§1 CEDH, alors qu'en droit français ce sont des autorités purement admin. Ce principe d'impartialité garanti par le DUE conduit à une réforme des mesures de sanction : l'art 6§1 exige une séparation des fonctions au sein du régulateur : séparation des fonction des sanction (souvent confiée à un organe indep au sein du régulateur) et on adapte les principes de la matière pénale à la régulation admin en transposant des principe pénaux à la matière admin (séparation fonction poursuite instruction et jugement qui est un principe fonda en procédure pénale et transposé à la fonction admin)

Si une autorité doit sanctionner un opérateur c très souvent le collège qui va faire ca puis poursuites confiées à un autre mec et sanction prononcée par la commission des sanctions